

SUCCESSIO

DERECHO HEREDITARIO ROMANO

**FRANJA
MORADA**

Reglamento de publicaciones - Anexo I Resolución 014/96 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas.

Art.74º "El o los autores serán los únicos responsables del contenido de las publicaciones..."

SUCCESSIO

DERECHO HEREDITARIO ROMANO

FRANJA MORADA

Autor: Dr. Mario A. Mojer

Diseño de Portada: Mario Lucio Mojer

Diagramación: *elsaBraun/dcv*

Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA

ISBN N° 950-863-020-5

Hecho el depósito que marca la Ley 11.723

Mario Antonio Mojer

SUCCESSIO

DERECHO HEREDITARIO ROMANO

FRANJA MORADA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA

Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas

*A mi esposa, Nélida
A mis hijos, Mario y Esteban*

FRANJA MORADA

INDICE DE MATERIAS

<i>Nota Introductoria</i>	Página
<i>Abreviaturas</i>	15
	17
CAP. I	
PRINCIPIOS GENERALES DE LA HERENCIA	
1.- Successio	19
2.- Universalidad	21
3.- Indivisibilidad	22
4.- Acrecimiento	23
5.- Clases de herederos	24
6.- Separatio Bonorum	25
7.- Delatio	27
8.- Aditio	27
9.- Herencia Pretoria	28
10.- Indignidad	30
11.- Herencia yacente	32
12.- Usucapio pro herede	33
	34
CAP. II	
SUCESION TESTAMENTARIA	
13.- Concepto de testamento	37
14.- Evolución de las formas testamentarias	39
15.- Testamentum militis	40
16.- Capacidad del testador	42
17.- Capacidad del heredero	43
18.- Institución de heredero	44
19.- Modos de instituir heredero	45
20.- Causas de invalidez	46
21.- Sustitución de herederos	47
	49
CAP. III	
Limites a la libertad de testar	
22.- Límites a la libertad de testar	53
23.- La sucesión legítima formal	55
24.- Bonorum possessio contra tabulas	56
25.- Sucesión legítima real	57
	57

FRANJA
MORADA

CAP. IV LEGADOS FIDEICOMISOS CODICILOS

26.-	Concepto de legado	61
27.-	Objeto de los legados	63
28.-	Clases de legados	64
29.-	Reducción de los legados	66
30.-	Fideicomisos	70
31.-	Codicilos	71
		73

CAP. V SUCESSION AB INTESTATO		
32.-	Capacidad del heredero ab intestato	77
33.-	La ley de las XII Tablas	79
34.-	Bonorum possessio	80
35.-	Senadoconsultos Tertuliano y Orficiano	83
36.-	Las Novelas 118 y 127	84
		85

CAP. VI ACCIONES HEREDITARIAS		
37.-	Hereditatis petitio	89
38.-	Defensa de los bonorum possessores	91
	a) Interdicto quorum bonorum	92
	b) actio hereditatis petitio possessoria	92
	c) Acciones ficticias	93
	d) interdicto quod legatorum	93
39.-	Medios judiciales en favor de los legatarios	95
40.-	Actio Familiae Eriscundæ	95
	Bibliografía	99

Nota Introductoria

Dos son los objetivos que me he propuesto con la publicación de esta obra. Por una parte la necesidad de su-
brayar, una vez más, la trascendencia del Derecho Romano, como disciplina fundamental destinada a la enseñanza de los principios generales del derecho. Principios, estos, in-
mutables que han mantenido su vigencia a través de los si-
glos y que continúan, aún hoy, aportando soluciones para los conflictos que se presentan ante los tribunales de los más evolucionados países del mundo. El segundo objetivo es la pretensión de mostrar el tema del derecho hereditario romano ante los alumnos de nuestras Facultades de Dere-
cho. Se ha querido, en pocas páginas, sintetizar un tema tan importante como el derecho sucesorio. En este sentido, es mi propósito reproducir por escrito las ideas generales sobre la materia, de la misma manera que se lo hace en cla-
se, tratando de transmitir solamente conceptos amplios. Por ello, aclaro que sobre los temas que componen el trabajo solo se realizan consideraciones generales, sin que ello sig-
nifique introducir al alumno dentro de discusiones profun-
das que sobre cada tema tuvieron los juristas romanos. Las citas bibliográficas son una muestra de lo expuesto ya que persiguen reflejar el origen de las fuentes sobre las que se basa el texto, pero también pretenden que el estudioso se sirva de ellas para profundizar los distintos temas. En sín-
tesis, se espera obtener de la obra un resultado positivo co-
mo es el conocimiento de las instituciones jurídicas básicas, que el alumno deberá tener en cuenta cuando su meta sea el conocer lo relativo al derecho sucesorio.

Abreviaturas

C	Código de Justiniano
CTh.	Código Teodosiano
D	Digesto de Justiniano
Fr. Vat.	Fragmentos Vaticanos
G:	Institutas de Gayo
Gel. N.A.	Aulo Gelio : Noches Aticas
Insts	Institutas de Justiniano
L.XII Tbs	Ley de las Doce Tablas
Nov.	Novelas de Justiniano
SC	Senadoconsulto
Ulp.	Reglas de Ulpiano

FRANJA
MORADA

FRANJA MORADA

1.- Successio

Para DONELO¹ la palabra *successio* tiene cuatro acepciones: 1º) el acto de suceder; 2º) la cosa susceptible de adquirir por sucesión; 3º) la cosa adquirida por sucesión; 4º) la cosa que sucede a otra cosa.

Successio, sucesión, desde un punto de vista extra-jurídico, significa entrar una persona o cosa en lugar de otra o seguir después de ella. En el plano jurídico sucesión es el subentrar de una persona en los derechos de otra.²

Los juristas postclásicos, tal vez influenciados por GAYO, consideraron al comprador, al legatario como verdaderos sucesores, y llamaron a esta sucesión *successio in unam rem*.³ En tanto, la denominación *successio* servía para designar la *successio in universum ius*.

Los juristas modernos, basándose en estos conceptos, hablan de una sucesión a título singular y una sucesión a título universal. La sucesión a título singular *inter vivos* posibilita la transmisión de la propiedad de un bien o de determinados bienes, tal como en el caso de la *mancipatio*, en que el adquirente continúa con los derechos que sobre la cosa tenía el transmitente.

En la época de Justiniano se conocía ya la sucesión particular o a título singular comprendiendo no solo el caso de la transmisión de un derecho propio a un tercero, sino también la constitución de un derecho a favor de otro que restrinja nuestro propio derecho, como por ejemplo la constitución de un usufructo.⁴

La sucesión a título singular *mortis causa* comprendería el caso de los legados, en el que se trasmite al legatario la propiedad de un bien o de un conjunto de bienes.

¹ DONELO : Libros de Comentarios sobre Derecho Civil. T. II, Libro 6, Cap. 22 II, folios 7, 8 y 9. Florencia, 1841

² DE CRESCENZIO : Digesto Italiano. Vol. 22, 3a parte, Cap. I. Torino, 1889

³ SCHULZ : Derecho Romano Clásico. I, 1, 370; p. 201. Casa Editorial Bosch, Barcelona, 1960

⁴ DI MARZO : Istituzioni di Diritto Romano. Milano, 1945

En tanto, la sucesión a título universal *inter vivos*, como en la *bonorum venditio*⁵, o *mortis causa*, como la herencia, va a comprender todos los bienes, todas las deudas y todos los créditos de las que era el causante propietario, deudor o acreedor.

2.- Universalidad

Una vez que el heredero ha adquirido la herencia no solo va a ser propietario de los bienes sino que va a continuar con la personalidad jurídica del difunto. GAYO sostiene que la herencia no es más que la sucesión en todo el derecho que tenía el difunto,⁶ concepto que coincide con la idea de ULPiano, quien afirma que el heredero tiene el mismo poder y derecho que el difunto.⁷

El heredero va a ser acreedor por todos los créditos y deudor por todas las deudas. Por eso se dice que la transmisión se va a operar a título universal, porque comprende el universo, todos los bienes corpóreos e incorpóreos. FADDA⁸ agrega que en la antigua sucesión romana el heredero ingresaba en el lugar del difunto, como jefe del grupo familiar: éste era el que debía responder por las obligaciones, o sea que estas últimas no eran propias del jefe de la familia sino del grupo en sí.

Con exclusión de aquellas relaciones jurídicas estrictamente personales, tales como la situación de marido, tutor, hijo, etc., u otras que por su naturaleza se extinguen en el momento de la muerte del causante, como el usufructo, el uso, la habitación o el mandato.

En cuanto a la posesión iniciada por el causante, és-

⁵ Procedimiento ejecutivo, propio del Derecho de Gentes, por el que se transmitía la totalidad del patrimonio del deudor al bonorum emptor.

⁶ GAYO, en D. 50, 16, 24.

⁷ ULPiano, en D. 50, 17, 59.

⁸ FADDA: Conceptos fundamentales del derecho hereditario romano. Milano, 1949.

ta no se trasmite *ipso iure* al heredero, pues es una situación de hecho. Pero si el heredero sigue la posesión, aprehendiendo la cosa, continua la *usucapio* iniciada por el causante.

En el período más antiguo de Roma el *Paterfamilias* solo tenía propiedad sobre sus bienes personales, sus armas, sus adornos. No así sobre los bienes que componían la *hereditas*, que era el patrimonio familiar, integrado por elementos patrimoniales y extrapatrimoniales, tales como los *sacra* (cosas destinadas al culto) y los *iura sepulchrorum* (derecho sobre los sepulcros familiares). Ello conlleva a la imposibilidad de partir la *hereditas* cuando moría el *Paterfamilias*. Lo que sucede en aquellas remotas épocas es que el nuevo *Paterfamilias*, al asumir la jefatura del grupo, no sólo recibe bienes patrimoniales sino también aquellos que no tienen contenido económico como la religión familiar, la veneración de los dioses Manes.

3.- Indivisibilidad

El principio de indivisibilidad parte de la existencia de las dos únicas clases posibles de herencia: la testamentaria y la intestada (*ab intestato*).

No habiendo testamento o resultando éste inválido, la ley regulaba un sistema sucesorio intestado designando los herederos.

Los dos sistemas sucesorios toman en cuenta un viejo principio de que nadie puede morir en parte testado y en parte intestado (*nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest*). Es decir que de existir herederos

instituidos por testamento no concurren a la sucesión los instituidos.

La institución de herederos debía hacerse por el todo de la herencia. De este modo quien instituía a los herederos por la mitad de la herencia no podía pretender que la otra mitad del acervo fuese a los herederos *ab intestato*. En tal caso, la sucesión es testamentaria y se considera que los instituidos lo han sido por la totalidad.

4.- Acrecimiento

Se trata aquí de la herencia en la que, a la muerte del testador, algún o algunos herederos no están en condiciones de adir la herencia, por incapacidad, renuncia o muerte. En tal caso, la parte que les correspondía a estos herederos acrecía en favor de los que la aceptaban, no transmitiéndose en favor de los herederos *ab intestato*. Dicho acrecimiento se producía en proporción a las partes del resto de los coherederos.

Esto, que se denominaba *ius adcrendi* (derecho de acrecer) proviene de dos de los principios básicos que gobiernan la herencia romana : 1) la *delatio* no se trasmite a los herederos del *delatus* (*hereditas delata*, *nondum adquisita*, *non transmittitur ad heredes*) y 2) nadie puede morir en parte testado y en parte intestado (*nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest*)

El derecho de acrecer se basaría, según Bonfante⁹, en el principio de la universalidad de la herencia. Se piensa que se aplican las soluciones que regulaban el derecho público: en el caso de las magistraturas estas eran colegiadas.

⁹ BONFANTE : Istituzioni di Diritto Romano. Dott A. Giuffrè Editore. Milano, 1987

Si uno de los magistrados estaba ausente, los otros asumían sus poderes. Lo mismo sucedía con los herederos : si uno de los coherederos no quería o no podía aceptar la herencia, los demás debían ocupar su parte.

El acrecimiento también puede aplicarse a las herencias *ab intestato*. Si alguno de los herederos legítimos no puede o no quiere aceptar la herencia, su cuota se transmite a los otros coherederos o a los que lo representen.

5.- Clases de herederos

Los herederos, según el *ius civilis*, son *sui*, necesarios o extraños. Los herederos *sui* (suyos) son los que se encuentran bajo la *patria potestas* del *Pater* al momento de la muerte de éste.

Entre los *sui* solo se incluyen los hijos legítimos, o sus descendientes si su padre ha muerto o ha cesado de estar bajo *patria potestas*. Hijos legítimos son aquellos que han nacido de justas nupcias.

Ello conlleva a excluir de la clase de los *sui* a los hijos emancipados y a los naturales, es decir los nacidos de concubinato.

El heredero necesario es el esclavo instituido heredero en el testamento. Es el esclavo que, al momento de la muerte del testador, se hace libre. En un principio, se exigía que el testamento contuviera la manumisión del esclavo, pero luego, en épocas de Justiniano se entendía que el solo hecho de instituirlo significaba su libertad.

La institución del esclavo respondía a solucionar algunas cuestiones de honor en aquellas herencias cuyos bienes no alcanzaban para pagar las deudas. En este caso aparecía el nombre del esclavo y no el del testador.

Los herederos extraños son aquellos que, en el momento de la muerte del *Pater*, no están sometidos a la *potestas* de éste. Son los hijos emancipados o los esclavos que, después de ser instituidos, han sido manumitidos.

La diferencia entre estas tres clases de herederos consiste esencialmente en la manera de adquirir o repudiar la herencia. Los *sui* y los necesarios no necesitan aceptarla, la adquieren de pleno derecho. En las primeras épocas no podían repudiarla, pero luego el Pretor les concedía, a su pedido, el *ius abstinendi*, el derecho de abstenerse de la herencia. En cambio los extraños, por eso también llamados voluntarios, pueden aceptarla o repudiarla.

Los extraños tienen la facultad de deliberar sobre la aceptación o la repudiación de la herencia (*deliberandi potestas*). En estos casos el heredero *ab intestato*, el sustituto, el legatario, o el acreedor podían instar al heredero para compelerlo a que aceptara o repudiara la herencia. En tal caso, el Pretor otorgaba al heredero un plazo no mayor a cien días y que luego Justiniano extenderá a nueve meses. Vencido el plazo, si los que reclamaban eran herederos *ab intestato* o sustitutos, se tenía al extraño como renunciante, invalidándose el testamento. Si la intimación provenía de acreedores o legatarios, se lo consideraba aceptante.

6.- Separatio Bonorum

En las llamadas herencias gravosas, en las que el heredero debía afrontar con su propio patrimonio las deudas de la herencia, aparece el denominado beneficio de inventario. Ello significaba que el heredero solo estaba obligado por las deudas hasta donde pudiera pagar con los bienes hereditarios. Este derecho, Adriano lo concedió solo a los menores de 25 años, luego el Emperador Gordiano lo extendió a los militares, concediéndolo Justiniano a todos los habitantes del imperio.

Para que el heredero pudiese gozar de este beneficio debía realizar un inventario de las cosas que componían la herencia, en presencia de un escribano, los acreedores y los legatarios dentro de los treinta días de que el heredero tomaba conocimiento de sus derechos y debía finalizar dentro de los sesenta días de iniciado.

De esta manera se terminaba con la confusión de patrimonios entre heredero y herencia, produciéndose la separación de los mismos (*separatio bonorum*)

7.- Delatio

La *delatio* es la imposición del título de heredero, su designación. El testador es quien realiza la *delatio* designando al heredero. Si no hay testamento, o es inválido será la ley la que designe al heredero.

Si existe testamento válido se considera hecha la *delatio* en el momento de la muerte del testador. Pero si el testamento es inválido, la *delatio* se realizará en el momento

en que se compruebe la ineficacia del testamento. Ello por aplicación del principio *nemo pro parte testatus, pro parte intestatus, decedere potest* (nadie puede morir en parte testado y en parte intestado) ¹⁰

Otro principio sostenido por los romanos los lleva a sostener que no existe sucesión en la *delatio*, es decir que si quien es designado como heredero muere antes de la *aditio*, no trasmite la herencia a sus herederos. Sin embargo también respecto de este principio, existen cuatro excepciones: a) *transmissio ex capite infantiae*. Si a quien se ha designado heredero muere en la infancia antes de adirla, le sucede su padre; b) *transmissio ex iure sanguinis*. Si quien ha sido heredero testamentario por un ascendiente, muere antes de adir la herencia, puede ser sucedido por un descendiente; c) *transmissio ex iure patris*. El *Pater* puede adir una herencia rechazada por su *filiusfamilias*; y d) *transmissio ex iure deliberandi*. Los herederos del heredero pueden adir la herencia dentro del año de la muerte de éste.

8.- Aditio

Adire es la forma verbal que significa aceptar la herencia por el que ha sido llamado a ella. Esta *aditio* (aceptación) podía efectuarse de tres maneras:

a) mediante una declaración solemne, realizada delante de testigos, llamada *cretio*. La *cretio* debía cumplirse cuando expresamente el testador la hubiera impuesto en el testamento. El heredero tenía un plazo para adir la herencia, que podía ser establecido por el testador pero nunca podía

¹⁰ Respecto de este principio existían algunas excepciones: 1) el testamento militar, que permite al testador instituir heredero por solo una parte de la herencia y destinar la otra a herederos *ab intestato*. 2) Si quien intenta la *querrela de testamento inoficioso*, como heredero *sui*, contra varios herederos testamentarios, gana el pleito en relación a unos y lo pierde contra otros. En este caso el sucesor legítimo tendrá que compartir la herencia con los herederos testamentarios que triunfaron. 3) Si el nieto, varón o mujer, o la hija han sido *preteritos* pueden concurrir con el heredero testamentario en hasta la mitad de la herencia (*ius adrescendi ad certam portionem*)

superar los cien días. Si el testador imponía un plazo mayor, el Pretor lo reducía a cien días ¹¹

La *cretio* es vulgar o continua. Si es vulgar el testador debe expresar que el plazo lo será a partir del momento en que el heredero se entera de la muerte del testador. Y es continua cuando no se dicen esas palabras, lo que significa que el plazo se contaba desde la muerte del testador.

También puede existir *cretio perfecta* o imperfecta, según si el testador percibe o no al heredero para que, en caso de no realizar la *cretio* sea o no desheredado.

En las sucesiones testamentarias donde no había plazo para la *cretio*, o en las sucesiones *ab intestato*, los acreedores del causante podían ir ante el Pretor para solicitarle que este fijase un plazo para la *aditio*. Si no había herederos que aceptaran la herencia se procedía a la *Bonorum venditio*.¹² Con Justiniano se entiende que vencido el plazo el heredero ha aceptado la herencia.

b) por una manifestación expresa no solemne (*aditio nuda voluntate*). Esto significa una manera informal de aceptar la herencia, mediante una declaración escrita o verbal, que indicaba la voluntad del heredero de adir la herencia. Así, por ejemplo, cuando el heredero poseía la herencia durante largo tiempo

c) por actos del heredero que implicaban la aceptación de una manera tácita (*pro herede gestio*). Estos actos debían demostrar la voluntad del heredero para aceptar la herencia. Así usar los bienes hereditarios como lo haría un heredero: vendiéndolos, cultivando el suelo o dándolos en arrendamiento.

¹¹ G : II, 170

¹² La *Bonorum venditio* era un procedimiento ejecutivo por el que el Pretor ponía a los acreedores en posesión de los bienes del causante, a fin de proceder a la venta del patrimonio. (G : III, 78)

9.- Herencia Pretoria

El excesivo rigorismo del sistema sucesorio de la ley de las Doce Tablas otorgó al Pretor la oportunidad de encauzar la sucesión hacia metas más justas. Este magistrado llamó a la herencia a aquellos que arbitrariamente eran excluidos por el derecho civil, conociéndose este sistema como *bonorum possessio*.

La *bonorum possessio* evitaba a los interesados el tener que ejercer un complejo trámite como era la *hereditatis petitio*, y les sustraía del peligro de que alguien ejerciese la *usucapio pro herede*. El beneficio de esta institución era tanto para los interesados en una sucesión testamentaria como si se tratase de una herencia intestada.

ULPIANO¹³ define la *bonorum possessio* como el derecho de reclamar y retener el patrimonio o las cosas que pertenecían al difunto en el momento de morir.

En el antiguo derecho civil había una serie de personas excluidas de la herencia. Entre otros, los *liberi emancipados*, los hijos de los peregrinos que habían sido declarados ciudadanos romanos sin haberseles otorgado la *patria potestas*, los cognados, como así también los agnados que sufrieren *capitis deminutio* perdiendo con ello la agnación.

A éstos el Pretor no los declaraba herederos pues con ello hubiese derogado o contradecido el derecho civil, siendo su objetivo completarlo. El llamado por el Pretor es *bonorum possessor* y no heredero, ya que no se les otorga la propiedad quiritaria sobre los bienes sino solo la posesión, pudiendo transformarse en propietario mediante la *usucapio*. El *bonorum possessor* no reemplazaba al causante.

¹³ ULPIANO en D. 37, 1, 3, 2

te en su personalidad jurídica, sino que el Pretor lo colocaba en el lugar del heredero (*loco heredu*).

El heredero adquiría la herencia *ipso iure*, de pleno derecho. En cambio, el *bonorum possessor* debía ir ante el Pretor y peticionar la posesión de los bienes. Los ascendientes o los descendientes debían peticionar la *bonorum possessio* dentro del año y las demás personas antes de los cien días.¹⁴ Estos plazos se computaban desde la muerte del causante o desde que se tuvo noticia de su fallecimiento.

La denominada *bonorum possessio secundum tabulas* estaba destinada a los herederos instituidos por testamento, cuando el testamento adolecía de ciertas formalidades.

En cambio, la *bonorum possessio sine tabulas* se configuraba cuando no había testamento y se destinaba la herencia a herederos del derecho civil o a parientes no contemplados por la ley de las Doce Tablas.

Se habla también de la *bonorum possessio contra tabulas*, situación ésta en la que se entregaba la posesión de los bienes a personas distintas a los que habían sido instituidos herederos.

En algunos casos se enfrentaban delante del Pretor los herederos con los *bonorum possessores*. Allí se distinguía entre *bonorum possessio sine re* - cuando el *bonorum possessor* debía ceder sus derechos ante las pretensiones del heredero - y *bonorum possessio cum re*, que significaba que el *bonorum possessor* convalidara sus derechos de tal forma que derrotara al heredero en la *hereditatis petitio*.

También podía distinguirse entre *bonorum possessio edictalis* - concedida por el Pretor en virtud de una cláusula que figuraba en el edicto - y la *bonorum possessio de-*

¹⁴ Ulp.: XXVIII, 10

cretalis, que acontecía cuando la situación no estaba prevista en el edicto y entonces el Pretor debía examinar el caso y luego de un prolijo examen podía concederla.

Se la concedía además por la *bonorum possessio ventris nomine*, destinada a la madre que tenía un hijo por nacer (*nasciturus*) y que cesaba al nacer el hijo o cuando se suponía que ya no nacería.

Bonorum possessio furiosi nomine, concedida al curador del *furiosus* hasta la muerte del insano o hasta el restablecimiento de su personalidad jurídica. Si el *furiosus* moría se consideraba como si nunca le hubiese sido otorgada.

Bonorum possessio ex Carboniano edicto, concedida a un impúber cuyo título podía ser objeto de controversia.

En ocasiones también podía concederse la *bonorum possessio* en razón de una condición todavía no cumplida.

Durante la última etapa del imperio - dominado - se terminan de unificar las diferencias que surgen de los derechos civil y pretoriano, subsistiendo la *bonorum possessio* solo como medida judicial provisional.

10.- Indignidad

El hecho de que se considerase un heredero indigno tenía como consecuencia que la herencia pasase a pertenecer al fisco. Se consideraba que en tal heredero había una conducta que no hacía digno de ser propietario de los bienes hereditarios.

En estos casos, el heredero podía llegar a la *delatio*, y aún a la *aditio*, pero una vez que adquiría los bienes el Estado los reivindicaba a su favor.

Varias eran las causales de indignidad, entre otras: homicidio del causante por el heredero; falta de asistencia al causante *furiosus*; impugnación infundada del testamento como inoficioso; falta de diligencia en el heredero para perseguir judicialmente a los asesinos del causante; *aditio* de la herencia antes del cumplimiento de lo dispuesto en el SC Siliciano¹⁵; incumplimiento de los legados y fideicomisos por parte del heredero; destrucción o falsificación de testamento.

11.- Herencia yacente

Denominase herencia yacente a la situación de la *hereditas* en el lapso que media entre la *delatio* y la *aditio*. Aunque sobre el concepto expresado no se registran dudas, sí existen varias posiciones acerca de la naturaleza de esta figura.

Desde las épocas más antiguas, se consideraba que en tal momento los bienes que integraban la *hereditas* eran *res nullius*, concepto éste que aparece luego confirmado por los juristas republicanos. Es decir que hay cosas, tal como lo dice GAYO, que no son de nadie, como las cosas hereditarias antes de que exista algún heredero.¹⁶

La situación de la herencia yacente daba lugar a problemas jurídicos, en ocasiones complejos, que los juristas clásicos resolvieron caso por caso. Tal como si se mataba a un esclavo de propiedad de una herencia. Entonces sur-

¹⁵ Por medio del SC Siliciano se disponía que, en caso de homicidio del causante, no conociéndose a los autores, se torturase a sus esclavos a fin de que delatasen a los asesinos. Si de las declaraciones de los esclavos se desprendía que éstos no habían colaborado para evitar la muerte del dominus debían ser condenados a muerte.

¹⁶ D. I, 8, 1, pr.

ge la pregunta de quien demandará por la ley Aquilia, ya que esta ley ordenaba que se indemnizase al dueño, a lo que CELSO responde que debía esperarse que alguien aceptara la herencia para poder ejercer la acción aquiliana.¹⁷

Otro caso a resolver es si la herencia yacente sustituye o no al causante. Así, en el supuesto de un esclavo que es propiedad de una herencia yacente los juristas se preguntan si el mismo puede ser instituido heredero. GAYO¹⁸ se pronuncia en forma afirmativa ya que el esclavo es de su dueña (la herencia) y ocupando ésta el lugar del difunto.

Y algunos textos romanos van más allá : se preguntan si la herencia yacente representa al difunto o al futuro heredero. POMPONIO¹⁹ afirma que las obligaciones del causante se transmiten al futuro heredero, aún cuando la herencia sea yacente. Y otros que esgrimen, para sostener que representa al difunto, la situación del esclavo que estipula en favor de su *dominus* que se encuentra cautivo. Si el dueño vuelve, la estipulación será válida , por el *ius postliminium*. Pero si muere en cautividad, la estipulación será nula.²⁰

12.- Usucapio pro herede²¹

Este peculiar instituto se piensa que nace en épocas muy antiguas y posibilita que el heredero extraño adquiera, por *usucapio*, los bienes de la herencia en el plazo único de un año.

Seguramente era un modo de compeler a estos herederos a adir la herencia, beneficiando a los acreedores para el cobro de sus créditos.

¹⁷ D. 9, 2, 13, 2

¹⁸ D. 28, 5, 31, 1

¹⁹ D. 46, 2, 24

²⁰ Inst. III, 17, pr

²¹ G. II, 54 y 55

La *usucapio pro herede* impone un plazo distinto al de la *usucapio*, que establecía un año para las cosas muebles y dos años para los inmuebles.

Luego, en tiempos de Adriano, un Senadoconsulto termina con esta forma de *usucapir*, disponiendo que el heredero disponía de la *hereditatis petitio* para reclamar la herencia y que tales bienes solo podían *usucapirse* singularmente, es decir respecto de cada bien en particular.

FRANJA MORADA

13.- Concepto de testamento

" La palabra *testamento* toma su origen de *testatio mentis*: testimonio de la voluntad. "22

La muerte de un sujeto de derecho no significaba en Roma la extinción de su personalidad jurídica. Y esto por- que los romanos imaginaban al difunto como disponiendo sobre su patrimonio, aún después de la muerte.

De allí entonces la importancia de este verdadero mandato *post mortem*, que era el testamento.

Todas las ordenes que contenía el testamento esta- ban destinadas a tener eficacia después de la muerte del tes- tador.

Y esto era muy importante en Roma ya que con el testamento no solo se transfería un patrimonio (con sus co- sas, sus bienes, sus créditos y sus deudas) sino también la jefatura política y religiosa de la familia. De allí que en las primeras épocas de Roma el testamento solo estaba destina- do a instituir un solo heredero. Este único heredero sustituía al *Pater* en el gobierno del grupo familiar

Por eso la trascendencia del testamento , el que di- fícilmente podía resultar inválido, dado que quien moría in- testado sufría una verdadera tacha social.

Diversas tesis sostienen la aparición de la sucesión testamentaria como anterior a la intestada, y otras, por el contrario, postulan la variable inversa. Hasta el momento, la polémica no encuentra respuestas certeras, ya que lo úni- co que aparece como dato seguro es que en la ley de las Do-

22 Insts. I, 10, pr.

ce Tablas aparecen los dos sistemas, testamentario e intestado. Sin embargo todo parece indicar la preeminencia de la sucesión testamentaria sobre la intestada. El modo normal de suceder, siguiendo los lineamientos de la particular idiosincrasia romana, era el testamento. Sólo si el testamento no se había dictado o si dictado era inválido, la herencia se transmitía de acuerdo a las disposiciones contenidas en la ley.

De lo dicho surge que debe entenderse el testamento como un acto solemne de última voluntad por el que se instituye heredero y se dispone sobre legados, manumisiones y tutelas.

En las fuentes romanas es posible arribar al concepto de testamento a través de la definición de Ulpiano: "El testamento es la manifestación legítima y acreditada de nuestro pensamiento hecha con las solemnidades debidas para que prevalezca después de nuestra muerte."²³

14. - Evolución de las formas testamentarias

Dos son los testamentos romanos más antiguos: el de paz y el de guerra. Al de paz se lo conoce como el testamento *calatis comitiis*. Era presentado ante el Comicio, reunido en asambleas especiales que se reunían dos veces por año para tratar, entre otros temas, los testamentos. Los ciudadanos que querían testar lo hacían en presencia del pueblo.²⁴

El testamento de guerra (*procinctu*) era el realizado ante el ejército sobre las armas. Quien iba a entrar en campaña, ante el peligro que las acciones bélicas podían entrañar para su vida, optaba por esta forma de testamento.

²³ Ulp. XX, 1

²⁴ "Los *comitia calatis* son los comicios celebrados en presencia de los pontífices, en los que tenía lugar la designación de los ritos religiosos anexos a las herencias y testamentos." (GELJO, N.A., XV, 27)

Posteriormente se añadió una tercera especie: el testamento *per aes et libram*. Todo parece indicar que esta nueva forma testamentaria fue adoptada, en un principio, por los plebeyos quienes no podían acceder fácilmente a las otras modalidades. Luego se convirtió en una forma generalizada que permitía eludir las dificultades de los testamentos antiguos. En este sentido, el inconveniente de que los *comitis calatis* solo se reunían dos veces por año, en tanto que la posibilidad de hacer testamento ante la inminencia de un combate dejaba fuera otras situaciones en que también estaba en peligro la vida.

Mediante este testamento se utilizaba la *mancipatio* para transmitir el patrimonio a quien sería el sucesor. Esto entrañaba los requisitos propios de la *mancipatio per aes et libram*: el trasmite, el adquirente, cinco testigos, el que sostenía la balanza (*libripens*), la balanza, el trozo de cobre y las palabras solemnes que debían pronunciarse.²⁵

Durante el principio, las dos formas más antiguas habían caído en desuso, extendiéndose el testamento *per aes et libram*, al que se le habían extendido ciertas modificaciones. Ello para subsanar los inconvenientes de lo riguroso de los efectos de la *mancipatio*, que no permitían al *familiae emptor* más que el título de simple adquirente del patrimonio familiar pero no el de heredero. Para ello se agregaban, en un segundo momento del acto, las palabras que consagraban la *nuncupatio*, manifestación verbal del testamento, pronunciadas por el trasmite.²⁶

El derecho pretoriano despojará luego al testamento de las solemnidades requeridas por la *mancipatio* y sólo se exigirán los sellos de siete testigos.

²⁵ "Yo me encargo por mandato tuyo de custodiar tu familia y tu fortuna, y a fin de que tu puedas en derecho hacer tu testamento de acuerdo con la ley pública, sean por mí compradas por esta moneda de cobre." (G. II, 104)
²⁶ "Tal como está escrita en estas tablas y en esta cera, así doy, así lego, así testifico y así pues daré vosotros quintos testimonio." (Ulp. XX, 9)

De estas formas surgirá el testamento imperial, conocido como tripérito porque reúne requisitos que provienen de los tres derechos. Del derecho civil la exigencia de testigos y la unidad de acto. Del edicto del Pretor los sellos de los testigos y el número de estos. Según el derecho civil eran cinco a los que se agregaron dos más, que eran simbólicamente el *libripens* y el *familiae emptor* del derecho imperial, las firmas del testador y de los testigos.

15.- Testamentum militis

En tiempos del imperio, diversas constituciones imperiales privilegiaban los testamentos realizados por militares. Se caracterizan estos testamentos por las normas excepcionales que se aplican respecto a su validez, sobre todo en relación a las formas, que diferían de las exigidas por el derecho civil.

Estos testamentos, para ser válidos debían ser realizados por soldados, o aún los civiles que estaban en campaña, pues si no estaba afectado a actividades militares debía cumplir con la totalidad de los recaudos dispuestos por el derecho civil. Si este testador era licenciado, el testamento solo conservaba su validez por el término de un año.

En cuanto al contenido, estos testamentos derogaban los principios generales que regían en el derecho civil. Así, los *filiusfamilias* podían testar, siempre que lo hiciesen en relación a los bienes que componían el peculio castrense. El principio *nemo pro parte testatus, pro parte intestatus, decedere potest*, no era obligatorio para este tipo de testamento, pudiendo el testador instituir heredero solo por una parte de la herencia, considerándose la otra parte como *ab intestato*. Tampoco era obligatorio el respeto por el prin-

cipio *semel heres semper heres*, lo que significa la posibilidad de instituir heredero bajo condición resolutoria. Para estos testadores no regían las normas de la *lex Falcidia*, las que daban viabilidad a la querrela de testamento inoficioso, o a la prohibición de preterir *heredes sui*.

16.- Capacidad del testador

“No es permitido a todos hacer testamento. Y después de luego, los que se hallan sometidos a la potestad de otro no tienen este derecho, de tal manera que no pueden legalmente testar ni aún con permiso de los jefes de familia. Si un hijo de familia hace testamento, ejecuta un acto inútil, aún cuando el testador antes de su muerte llegase a ser jefe de familia.”²⁷

Ello significa que los hijos de familia no pueden testar, salvo que lo hagan respecto de los bienes que componen su peculio castrense o cuasicastrense.

Tampoco tenían capacidad para testar los esclavos, con excepción de los esclavos públicos, que podían disponer por testamento por la mitad de su peculio.²⁸

Los libertos, en la época de la ley de las Doce Tablas, no tenían el derecho de testar. Luego, en virtud de la ley *Ælia Sentia* con la que surgen tres categorías de manumitidos (ciudadanos romanos, latino junianos y dedíticos) solo pueden hacerlo los libertos que pertenecen a la primera categoría.

La capacidad en el testador debe existir en el momento del testamento y hasta el momento de la muerte. Si el testador estaba demente al momento de hacer su testa-

²⁷ Insts. II, 12, pr.
²⁸ Ulp. XX, 16

mento, éste es inválido. Pero es válido si estaba sano en el momento del testamento y después se vuelve loco.

Si quien ha testado válidamente pierde luego su capacidad por una *capitis diminutio*, invalida esta circunstancia el testamento. Salvo el caso de quien es apresado por el enemigo que, en virtud de la ficción de la *lex Cornelia* consideraba el comienzo de la cautividad como el momento de la muerte, validando el testamento dictado con anterioridad.

17.- Capacidad del heredero

Los peregrinos, los deportados, los dediticios, los latino junianos²⁹, no pueden ser herederos testamentarios. Tampoco las mujeres, por efecto de la *lex Voconia* (170 aC); los célibes(solteros varones entre los 25 y los 60 años y mujeres entre los 20 y los 50 años), en virtud de la *lex Julia*, como así tampoco los *orbi* (casados sin hijos) , por prohibición emanada de la *lex Papia Poppaea*. A estas leyes se las denominó caducarias pues hacían caducar los derechos hasta la mitad de la herencia, la que pasaba al Fisco. Domiciano extiende la incapacidad para suceder a las mujeres meretrices y a las de teatro.

No pueden ser instituidos los dioses, excepto aquellos que por Senadoconsulto, o por constituciones del Príncipe admiten su institución, como, entre otros, Jupiter, Tarpeyo, Némesis. ³⁰

Los póstumos pueden ser instituidos, siempre que se trate de póstumos *sui*. Los *postumi alieni*, que habían nacido fuera de la familia del testador no podían ser instituidos.

²⁹ Salvo que, al momento del fallecimiento del causante o en el plazo de cien días a partir de la defunción, obtengan la ciudadanía romana.

³⁰ Ulp. XXII, 6

Tampoco pueden ser instituidas las personas inciertas, es decir aquellas personas que no están determinadas con precisión por el testador. Tal el caso expuesto por Ulpiano :

“Cualquiera sea el que llegue primero a mis funerales sea heredero.”³¹

La mayoría de estos impedimentos aparecen derogados en la época de Justiniano.

18.- Institución de heredero

La institución de heredero (*heredis institutio*) es el requisito intrínseco esencial del testamento romano. Si no se ha instituido heredero, el testamento carece de validez.

En el testamento, la institución de heredero debía colocarse en primer lugar. Si en el texto aparecían primero los legados, las manumisiones, el testamento no tenía efecto.

Los legados hechos antes de la institución de heredero son inútiles ya que los testamentos , como es sabido, reciben su fuerza de la institución de heredero y es por esta razón que se entiende que ésta es el principio y fundamento de todo testamento. (G.: II, 229)

“ Por la misma razón es que no se pueden otorgar manumisiones antes de la institución de heredero.” (G.: II, 230)

La institución de heredero debía redactarse en términos imperativos, pues otras formas no son admitidas.

La institución solemne es ésta : Titius, se heredero; pero se tiene también por admitida esta otra: Ordeno que

³¹ Ulp. XXII, 4

Titius sea heredero. En cambio, no se considera aprobada: Quiero que Titius sea heredero; estando también desechada: Instituyo a Titius como heredero; o también: Hago heredero. (G.: II, 117)

Ello por la misma naturaleza del testamento, cuyo contenido, en especial la *heredis institutio*, consiste en una orden, y por lo tanto no puede consistir en frases no imperativas. Este formalismo resulta luego derogado por Constantino II.

19.- Modos de instituir heredero

“La institución de heredero puede hacerse puramente o bajo condición, pero no desde un término fijo, ni hasta un término fijo.” (Insts. II, 14, 9)

Si al heredero se lo instituye como puro y simple, ello significa que no está su institución sujeta a condición ni a plazo. En tal caso adquiere la herencia desde el momento de la muerte del testador. En cambio, para el heredero instituido bajo condición su derecho comienza el día del cumplimiento de la condición, salvo que la condición ya se hubiese cumplido en vida del testador. En tal caso, el derecho del heredero comienza, como en el heredero puro y simple: el día de la muerte del testador. Solo se admitían las condiciones suspensivas (Se mi heredero el día que se venda el fundo). Pero no era válida la *heredis institutio* si se la subordinaba a una condición resolutoria (Se mi heredero hasta que llegue la nave del Asia)

Si la institución de heredero estaba subordinada a un término o plazo, tal cláusula se tenía por no escrita. Así, el testador no podía expresar, por ejemplo: Que Ticio sea

mi heredero cinco años después de mi muerte, o desde tales calendas o hasta tales calendas., como una forma de plazo suspensivo ni tampoco a título de plazo resolutorio: Que Ticio sea mi heredero por cinco años. En cambio se admitía el plazo *incertus*: Se mi heredero a partir de la muerte de Sempronius.

Estas disposiciones respondían al principio *Semel heres semper heres* (una vez heredero siempre heredero).

Lo mismo sucede con las condiciones imposibles, las que se consideran no escritas, considerándose al heredero puro y simple.

“La condición imposible en las instituciones, legados, fideicomisos y manumisiones se considera no escrita.” (Insts. II, 14, 10)

Así, por ejemplo, si la institución de heredero se condiciona a que el heredero se beba toda el agua del Tíber.

También se consideraban no escritas las condiciones contrarias a la ley o a las buenas costumbres (Se mi heredero si matas a Flavio)

20.- Causas de invalidez

Sobre el tema, pensamos que la postura de AMBROSIONI³² no admite dudas: “Los romanos no conocieron una acción declarativa de nulidad por lo que en su sistema, a través de las diferentes fases por las que ese derecho pasó, el acto era inexistente o válido”.

Por ello preferimos hablar de invalidez y no de nulidad. Invalidez que impedía que el testamento produjera sus efectos y que traía como consecuencia que la sucesión se transformase en intestada.

³² AMBROSIONI: Ensayo sobre una sistematización de los hechos y actos jurídicos en el derecho romano. Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Tomo XXI, año 1962, p. 135

La categoría de actos nulos y anulables quizás no haya sido conocida por los juristas romanos, pero si por los comentaristas posteriores del *Corpus Iuris Civilis*.

En el derecho quirritario el acto existía o no existía. En cambio, en el derecho honorario aparecen la *in integrum restitutio* o la *exceptio* como remedios procesales que pueden invalidar un acto, en principio eficaz.

Sin perjuicio de lo expuesto, no reuniendo el testamento las formalidades exigidas por el *ius civile*, este podía ser convalidado por el Pretor por medio de la *Bonorum possessio cum re*.

Lo de nulo o anulable no puede aplicarse en Derecho Romano, donde solo pueden observarse algunos casos aislados de conversión en ciertos negocios jurídicos. Así el SC Neroniano, que convierte en legado *per damnationem* aquellos legados *sinendi modo*, *per præceptionem* o *per vindicationem* que no reunieran los elementos esenciales.

Tal como dice BETTI³³, no puede hablarse de una verdadera conversión porque sigue siendo el mismo negocio jurídico al que se le atribuyen los efectos que por el derecho civil debió tener de no mediar la causa que lo anulaba, tal como sucede en virtud de las normas del SC Neroniano. En estos casos la conversión tiene lugar por vía de interpretación, interpretación que realizaban los juristas.

Diversas eran las causas que provocaban la invalidez del testamento. Los testamentos, para ser válidos debían cumplir con todos los requisitos que emanaban de las distintas disposiciones legales.

Pero había testamentos que, aún cumpliendo todas las formalidades no producían efectos. Así se denominaba testamento inútil cuando se había preterido *heredes sui*.

³³ BETTI: Istituzioni di Diritto Romano. Padova, 1947

El testamento era *ruptum* (roto) por dos causas: a) por haberse dictado un testamento posterior; b) en aquellos casos en que existía preterición sobreviniente, es decir posterior al testamento. Ello acontecía cuando al testador, después de testar, le nace un hijo. O también por muerte o emancipación del hijo del testador, existiendo nietos que lo representen. O por haber el testador, después del testamento, adoptado o adrogado a alguien como hijo o como nieto.

El testamento se consideraba *irritum* en el caso de que el testador, después de realizado, sufriera una *capitis deminutio*. Ello por haberse modificado alguno de sus tres *status*, al haber perdido su libertad (*status libertatis*), su ciudadanía (*status civitatis*) o en razón de haber variado su *status familiaris*, por haber sido adrogado.

También es inválido el llamado testamento *desertum*, causal producida por no existir herederos en condiciones de aceptar la herencia.

21.- Sustitución de herederos

De lo expuesto hasta ahora fácilmente puede deducirse la importancia que tenía para los romanos el realizar un testamento válido, a fin de conjurar el peligro de la deshonra ante una sucesión intestada. El riesgo del testamento *desertum*, seguramente, habrá hecho nacer la figura de la sustitución de herederos. Ello con el propósito de que, en caso de no ser aceptada la herencia por el heredero instituido, alguien lo sustituya. Se trata, entonces, de una subinstitución de heredero sujeta a condición.

Dicha sustitución podía ser vulgar o pupilar. Respecto de la primera, era la más amplia, ya que instituía a un

heredero y designaba a quienes lo sustituirían en el caso de que no fuese aceptada la herencia, el heredero no tuviese capacidad o hubiese premuerto al testador. Aún cuando las sustituciones de herederos provenían del antiguo derecho romano, muchos más frecuentes se hicieron en el período imperial, ya que existían leyes, como las caducarias, que inhabilitaban, por distintas razones, a los herederos.

“Se pueden constituir en un testamento muchos grados de herederos, como, por ejemplo: Si aquel no fuese heredero, que lo sea este; y así en otros casos, haciendo tantas instituciones cuantas quiera el testador. Puede aún este, en último lugar, y como recurso subsidiario, instituir a uno de sus esclavos heredero necesario.”³⁴

Acerca de la institución del esclavo resulta interesante la aclaración que hace PAULO³⁵, en el sentido de que si se tratase de un testador insolvente e instituya heredero al esclavo y designaba un sustituto, el sustituto era heredero, pues la ley *Ælia Sentia* solo permitía que el que fue instituido en fraude de los acreedores solo conservaba la libertad si ningún otro podía ser heredero.

La sustitución no significaba el acrecimiento cuando en caso de ser varios los herederos instituidos, el testador hubiera dispuesto la sustitución de otro sujeto por uno de ellos. Así lo explica VOLTERRA³⁶: Si el testador instituyó herederos a Ticio, Cayo y Sempronio, estableciendo que si Ticio no pasaba a ser heredero fuera heredero Mevio, no aceptando o no pudiendo aceptar la herencia Ticio, su cuota no pasaba a acrecer la de los coherederos, sino que era adquirida por el sustituto. Pero si, en cambio, el testa-

³⁴ Insts. II, 15, pr.

³⁵ D. 28, 5, 57

³⁶ VOLTERRA: Instituciones de Derecho Privado Romano. Civitas, Madrid, 1986. p. 741, nota 136

dor instituyó a Ticio, Cayo y Sempronio, disponiendo que, si los tres no pasaban a ser herederos, fuera heredero Mevio, cuando uno o dos de los tres instituidos no adquirían la herencia sus cuotas acrecían la de los instituidos o la del instituido que quedaba.

La sustitución era pupilar cuando el testador instituyó heredero a un *filiusfamilias* impúber y nombraba un sustituto para el caso en que el impúber muriera antes de la pubertad.

Esta segunda forma de sustitución responde a la necesidad de evitar una doble sucesión intestada, la del *Pater* y la del *filius*, ya que este último no podría testar antes de alcanzar la pubertad.

GAYO aclara que se trata de un solo testamento, pero de dos herencias (G: 2, 180)

Si el hijo se hace heredero pero muere antes de la pubertad, el sustituto se hace heredero del hijo.

De fines de la república proviene la polémica acerca del *filius* impúber que no pasaba a ser heredero, y si en esos casos se consideraba a la sustitución pupilar como convertida en vulgar.

Ello dio origen a la conocida causa Curiana, que fuera sometida al Tribunal de los Centumviro. El pleito proviene de Coponio, quien en su testamento instituyó heredero a su hijo por nacer, designando sustituto pupilar a Manlio Curio. Acaecida la muerte de Coponio, sus herederos ab intestato, no habiendo nacido el hijo, después de transcurridos diez meses fueron ante el Tribunal a fin de reclamar la herencia.

Estos herederos sostenían que la sucesión debía tenerse como intestada, ya que nadie podía ser sustituto pupilar de alguien que no había nacido.

El Tribunal terminó otorgando la herencia a Curio. Para ello sostuvo que debía investigarse la intención del testador y que en este caso debía considerarse la sustitución como vulgar.

El Tribunal tenía ante sí dos soluciones posibles. Aplicando el criterio objetivo, el de examinar la estricta letra del testamento - que contenía expresamente una sustitución pupilar - la herencia debía ser otorgada a los herederos *ab intestato*. Pero el fallo fue el resultado de la interpretación subjetiva. El testador había querido que su herencia no fuese intestada y para eso designó un heredero sustituto, considerando que la sustitución pupilar, en este caso, implicaba la vulgar.

22.- Límites a la libertad de testar

La evolución de la materia parece partir de la ley de las Doce Tablas: " Tal como legase acerca de los bienes y del cuidado de sus cosas, así sea derecho " (V, 3), texto que es reproducido por GAYO :

" Antiguamente, era por cierto lícito gastar todo el patrimonio en legados y en manumisiones, de tal modo que al heredero solo le quedaba el mero nombre de tal. Así parecía permitirlo la Ley de las XII Tablas, que disponía que cualquier cláusula testamentaria relativa a las cosas del testador debía ser respetada; estas eran las palabras de la ley : así como dispusiera de sus cosas, tal será el *ius*. " (Gayo: II, 224) y del que algunos han interpretado la existencia de una amplia libertad de testar (*uti legassit super pecunia tutelave suae rei ita ius esto*) en el sentido que el testador de aquellas épocas podía disponer libremente en relación a la institución de heredero, como así también sobre los legados, manumisiones y tutelas.(D. 50, 16, 120)

Sobre el verbo *legare*, DI PIETRO³⁷ sostiene que no hay que darle un sentido técnico restringido: hacer legados; sino un sentido lato, en el cual quedaría comprendido: ordenar a alguien por acto *inter vivos* la disposición *post mortem* de nuestro patrimonio.

Esta que parece la idea de la libertad absoluta del testador, no resulta de interpretación unánime: se piensa que la disposición original sería la que se contiene en GAYO : II, 224 y D. 50, 16, 120, que habría de ser entendida en el sentido restrictivo de que *suae rei* son solo las cosas personales del testador, es decir sus armas o sus adornos personales de los que puede disponer a título particular, no

³⁷DI PIETRO: Traducción y Notas a las Institutas de Gayo. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1987

FRANJA
MORADA

pudiendo hacerlo sobre el patrimonio que podríamos llamar familiar, afecto al sustento del grupo.³⁸

Por otra parte, lo de la falta de límites a la libertad de testar resulta a todas luces incomprensible, sobre todo en el período primitivo en que los testamentos eran sometidos a la aprobación del pueblo (*calatis comitiis*) La intervención de los comicios en esta materia solo puede ser atribuida a la importancia que la *civitas* otorgaba a la designación del *Paterfamilias*, auténtico conductor del grupo familiar.

Lo cierto es que desde el derecho antiguo, pasando por el derecho pretoriano y culminando en la etapa postclásica, Roma ha creado una serie de recursos legales que han limitado la supuesta libertad absoluta del testador. Siguiendo el esquema de SCHULZ³⁹, se plantean tres remedios legales para atenuar aquellas disposiciones testamentarias que lesionan los derechos de los herederos : 1º) La sucesión legítima formal; 2º) Bonorum Possessio contra tabulas; 3º) Sucesión legítima real.

23.- la sucesión legítima formal

La sucesión legítima formal, a la que los pandectistas alemanes denominan sucesión necesaria formal, institución basada en el principio de ULPiano⁴⁰ y en la que se invalida el testamento en que se hubiesen preterido *sui heredes* (testamento *inutile*) Esta amplitud en el ejercicio de la *testamenti factio* activa, en el sentido de instituir o desheredar libremente, en épocas primitivas seguramente provenía de la necesidad de instituir un solo heredero como medio de otorgarle la jefatura del grupo familiar, atento la implicancia política del mismo dentro de la *civitas*.

38 RASCON GARCIA y GARCIA GONZALEZ: Ley de las XII Tablas. Tecnos, Madrid, 1993.

39 SCHULZ: Derecho Romano Clásico. Casa Editorial Bosch, Barcelona, 1960.

40 Ulp., XXII, 14 (Los herederos suyos deben ser instituidos o desheredados)

24.- bonorum possessio contra tabulas

La *bonorum possessio contra tabulas testamenti*, por medio de la cual el Pretor extiende los principios de la sucesión legítima formal a los emancipados.

“ En cuanto a los emancipados, el derecho civil no considera necesario que se los instituya herederos o se los desherede, ya que no son *sui heredes*, pero el Pretor ordena que si no son instituidos herederos, se los debe desheredar a todos, tanto a las mujeres como a los varones, estos en forma nominativa, aquellas en forma nominativa o colectiva, ya que si no hubieran sido instituidos herederos, o como dijimos más arriba desheredados, el Pretor les ofrece la *bonorum possessio contra tabulas*. (GAYO: II, 135)

25.- sucesión legítima real

La sucesión legítima real o también denominada sucesión necesaria material, por la que se dispone la invalidez del llamado testamento inoficioso, cuando el testador ha infringido sus deberes respecto de sus parientes más próximos (*officium pietatis*) preteriéndolos, desheredándolos sin justa causa o asignándoles una escasa proporción.

Nos detendremos en esta última, atento su peculiar naturaleza jurídica y el modo de resolver esta cuestión por parte de los tribunales romanos.

En la última época de la república, quienes resultaban perjudicados por un testamento inoficioso recurrían mediante la querrela *inofficiosi testamenti*, que no provenía de una solución legislativa, sino que era una creación jurisprudencial., propia del tribunal de los centumviro.

Esta querella se tramitaba mediante un procedimiento que se apartaba de las reglas generales y otorgaba un amplio margen al arbitrio del juez. Según KASER⁴¹, esta querella no plantea una cuestión jurídica, sino más bien el problema de determinar si se ha quebrantado o no un uso social, razón ésta que justifica que la solución dependa del arbitrio del juez y que permite un empleo a fondo de la oratoria.

Se entendía que, en el testamento inoficioso, el testador había obrado como si no hubiese estado en su sano juicio (*color insanitæ*) en una apariencia de insania.

“Se demanda por testamento inoficioso con el pretexto de que los testadores no estaban en su sano juicio al ordenar el testamento y esto no se dice en el sentido de que realmente un loco o un deficiente mental haya hecho testamento, sino el que una persona hizo testamento legalmente pero no de acuerdo con los deberes que el afecto familiar impone, pues si realmente se trata de un loco o de un deficiente mental, el testamento es nulo.” (D.5.2.2)

Al carecer el procedimiento de sustento legal, el Tribunal debía tener en cuenta las circunstancias de cada caso, a fin de llegar a establecer si el testador había o no faltado a sus deberes familiares. LA PIRA⁴² sostiene que el objeto de la querella, en la época clásica no es otro que el de rescindir el testamento en cuanto es causa de injuria para el legítimo, y en los límites a que esto alcanza.

El examen de los motivos que conducían a que el Tribunal determinase que la desheredación había sido justa o arbitraria, se dejaban a su arbitrio, teniendo en cuenta las circunstancias del caso. Luego sería la Novela 115 la que

41 KASER: Derecho Romano Privado. Instituto Editorial Reus, Madrid, 1968

42 LA PIRA: La successione ereditaria intestata e contro il testamento in diritto romano. Florencia, 1930.

determinaría con precisión cuáles eran las causales válidas para la desheredación.⁴³

Procesalmente, la querella *inofficiosi testamenti* era en realidad una *hereditatis petitio ab-intestato*, acción esta que ya existía en la época de las *legis actionis*, pero con algunos principios propios.⁴⁴ La querella solo podía ser ejercida contra el heredero instituido, por los descendientes o los ascendientes del testador no siéndoles concedida a los hermanos y hermanas consanguíneos salvo que se hubiese preferido a ellos una persona vil.⁴⁵

Si el querellante triunfaba el testamento era anulado, pudiendo obtener la cuota que le correspondía como heredero *ab intestato* mediante la *hereditatis petitio*. Pero si no obtenía sentencia favorable, el querellante, dada su calidad de indigno, perdía todas las liberalidades obtenidas por el testamento, yendo las mismas al fisco.⁴⁶ Esta sanción se imponía seguramente por considerarse una verdadera injuria el haber demandado al causante para torcer su voluntad testamentaria.

43 Nov. 115: “Estas causas respecto de los hijos son catorce: 1) Si el hijo ha injuriado a su padre gravemente; 2) si le ha dado golpes; 3) si ha atentado contra su vida; 4) si por su delación le ha causado perjuicio; 5) si vive en compañía de malhechores; 6) si ha querido impedir que su padre haga testamento; 7) si lo ha abandonado en la locura; 8) si no lo ha rescatado estando cautivo; 9) si el hijo es hereje; 10) si ha acusado a su padre de un crimen capital; 11) si ha tenido relaciones ilegítimas con su madre; 12) si ha acusado a su padre; 13) estando su padre preso por deudas, negarse su hijo a ser su fiador; 14) si el hijo tiene una vida licenciosa, habiendo su padre ofrecido casarla y dotarla. - Respecto de los ascendientes, las causales son ocho: 1) si han acusado a sus descendientes por un crimen que merezca pena capital; 2) atentado contra su vida; 3) haber tenido comercio con la mujer o concubina de sus hijos; 4) puesto obstáculo a que hiciesen testamento; 5) si no los han rescatado del poder del enemigo; 6) si en caso de denuncia los han abandonado; 7) por causa de hereje; 8) si el padre ha querido envenenar a la madre o al contrario.”

44 PEROZZI (Istituzioni di Diritto Romano. G. Barbera Editore, Florencia, 1908) sostiene que la querella no es una *hereditatis petitio* ordinaria, sino particularmente calificada.

45 “... *turpilius personis*...” el texto se refiere a los histriones, los gladiadores, las prostitutas y a las personas con nota de infamia (Inst.: II, 18, 1)

46 VOLTERRA: Instituciones de Derecho Privado Romano. Civitas, Madrid, 1986.

Quien estaba entre los legitimados y no había sido ni desheredado ni preterido, pero hubiese recibido una parte excesivamente escasa de la herencia, también podía interponer la querrela cuando su parte era inferior a la cuarta parte de lo que le hubiera correspondido por sucesión *ab intestato*.

Este cuarto, explica TALAMANCA⁴⁷, no era una cuota de reserva. La querrela estaba destinada a rescindir el testamento y a la posterior apertura de la sucesión *ab intestato*, consiguiendo el querellante un beneficio mayor que aquel que el testador había dispuesto.

Esta porción legítima (portio debito) parece provenir de la *lex Falcidia* que había dispuesto que los legados no podían superar las tres cuartas partes de la herencia, previa deducción de las deudas, las manumisiones y los gastos.

En un principio el Tribunal de los centumviros, frente al triunfo de la querrela, solo tenía como solución invalidar el testamento, decretándose la apertura de la sucesión intestada. Ello por aplicación del principio *nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest*, que impedía la concurrencia de los herederos testamentarios junto a los herederos *ab intestato*.

Tal vez por estas razones y los graves perjuicios que devenían de la invalidación total del testamento, es que aparece una acción - *actio ad supplendam legitimam* - que impide el ejercicio de la querrela en aquellos casos en que el heredero ha recibido una parte menor a la *portio debita*, completando la misma. (C.Th. 2, 19, 4)

⁴⁷TALAMANCA: Istituzioni di Diritto Romano. Dott. A. Giuffrè Editore, Milano, 1990

26.- Concepto de legado

El legado es una disposición testamentaria emitida a título singular, ya que no responde al principio de universalidad. El legado comprende parte de la *hereditas*, pero no involucra el todo.

ULPIANO⁴⁸ define al legado como aquello que es como ley, esto es, lo que imperativamente se deja en un testamento. .

En *Institutas*, el legado aparece como una especie de donación dejada por un difunto,

En todo legado deben tenerse en cuenta tres sujetos: el testador (disponente) el heredero (*oneratus*) y el legatario (*honoratus*). El heredero es quien debe ocuparse de que se cumpla la voluntad del testador. El legatario es quien resulta destinatario del legado. Debe tenerse en cuenta que el legado no es requisito esencial del testamento, estando subordinado a la eficacia del testamento. No siendo el testamento válido no lo es tampoco el legado.

La validez del legado está implícitamente condicionada a la *adiitio* de la herencia por parte del heredero instituido. Esta situación de expectativa se transmite a los herederos del legatario, si éste muere.

En el tema habrá que tener en cuenta dos momentos: el *dies cedens*, que es el momento en que el legatario comienza su situación de expectativa ("Ceder el día quiere decir que empieza a deberse la cantidad."⁴⁹) y el *dies veniens*, que marca el día en que el legado se torna exigible para el legatario. ("Venir el día, significa que ha llegado el momento en el que se puede exigir la cantidad."⁵⁰)

⁴⁸ Ulp. XXIV, 1

⁴⁹ D. 50, 16, 213, pr.

⁵⁰ D. 50, 16, 213, pr.

Originariamente el *dies cedens* coincidía con el momento de la muerte del testador. Luego en virtud de la *lex Papia Poppæa* y otras leyes caducarias, se desplaza hasta el momento de la *adiitio* por parte del heredero. Justiniano vuelve a la posición original al sostener: *dies legati cedit morte testatoris*.

El legado hecho en favor de un esclavo o de un *filiusfamilias* pasa a ser del *dominus* o del *Pater*, aún cuando antes de la *adiitio* el esclavo sea manumitido o el *filius* se haya emancipado.

Si el legado era condicional, el *dies cedens* se desplaza al momento del cumplimiento de la condición. Por ende, si el legatario moría antes del cumplimiento de la condición, el derecho de expectativa del legatario no se transmitía a sus herederos.

Tanto en el legado dispuesto en favor de un esclavo que se manumite en el testamento, como en el legado de usufructo, el *dies cedens* se cumple en el momento de la *adiitio*, coincidiendo tal momento con el *dies veniens*.

En los legados sujetos a término, el *dies veniens* se verifica en el momento del vencimiento del término.

27.- Objeto de los legados

Los romanistas suelen clasificar los legados según el objeto de cada uno de ellos. Así han denominado:

a) *Legatum generis*: es el legado cuyo objeto son cosas fungibles. Tal como dice GAYO⁵¹ son aquellas cosas que pueden ser pesadas, medidas o contadas. En los legados *per damnationem* la elección de la cosa corresponde al heredero.

51 G. II, 196

ro. En los legados *sinendi modo*, *per præceptionem* y *per vindicationem*, la elección será del legatario. En el legado *per damnationem*, la cosa podía no pertenecer al patrimonio del causante, es decir podía estar fuera de la *hereditas*. ULPIANO⁵² afirma que cuando se dispone un legado genérico, por ejemplo cuando se lega un esclavo sin decir cual, no hay que entregar ni el mejor ni el peor.

b) *legatum speciei*: por el que se debe entregar cosas no fungibles, es decir una cosa determinada - un caballo, un buey, o un esclavo determinados. o una universalidad de cosas - un rebaño. Si el heredero no puede entregar la cosa, deberá entregar su valor⁵³.

c) *legatum nominis*: este legado es propio de los denominados *per damnationem*. El heredero se obliga a ceder al legatario un crédito que era del causante. De este modo, el heredero le cede al legatario las acciones que el causante tenía contra el deudor. El crédito funciona aquí como elemento principal, siendo el legado el elemento accesorio. Así, si el crédito es inexistente, el legado será ineficaz.⁵⁴

d) legado alternativo: Es el legado en que el legatario debe elegir entre dos o más cosas, salvo que en el testamento estuviese previsto que la elección le corresponde al heredero. Si el legatario muere sin haber elegido, su derecho se transmite a sus herederos.

e) *legatum optionis*: mediante este legado el testador dispone que sea el legatario quien realice la elección de una cosa entre varias. Si el legatario no realiza la elección, este derecho no se transmite a sus herederos y por tanto el legado se torna ineficaz.

f) *legatum liberationis*: este legado tiene por objeto la liberación del legatario.

52 D. 30, 37, pr.

53 D. 30, 45, 2; D. 30, 21 y 22

54 Insts. II, 20, 21

ración del legatario respecto de una deuda que este tenía con el causante o con un tercero. ⁵⁵

g) *legatum partitionis*: por medio de este legado el testador dispone que una parte de la herencia vaya al legatario. ⁵⁶ Según Justiniano el heredero, en tal caso, podía elegir entre entregar al legatario la parte o el valor de la misma, median-
te *æstimatio*.

h) legado de prestaciones periódicas o de alimentos: en am-
bos casos se trata de la obligación del heredero de entregar
periódicamente al legatario una suma de dinero determi-
nada. Aquí el testador debe determinar con precisión cual
es el monto de la suma total, la frecuencia conque se debe
entregar y el plazo, ya que en algunos casos estas sumas se
entregaban hasta la pubertad del legatario. ⁵⁷

i) prelegado: es el legado dispuesto en favor de uno de los
herederos y que estaba a cargo de uno de los otros cohere-
deros. Este legado sería ineficaz de existir un solo herede-
ro, ya que no podría darse la situación de ser un sujeto par-
te activa y pasiva al mismo tiempo.

28.- Clases de legados

Los juristas romanos distinguen cuatro clases de le-
gados que, en realidad, responden a la forma en que se ha
dispuesto y, por ende, entrañan efectos jurídicos distintos.
a) *legatum per vindicationem* (legado de disposición).

“Se lega *per vindicationem*, de este modo: DOY, LEGO A
TITUS MI ESCLAVO STICHUS; pero si emplea uno
cualquiera de los dos verbos, es decir DOY o LEGO, lo
mismo se ha legado *per vindicationem*; igualmente se con-

⁵⁵ D. 34, 3

⁵⁶ Ulp. XXIV, 25

⁵⁷ D. 33, 1 y D. 34, 1, 14

sidera aprobado por la mayoría que si se ha legado así: TO-
MA, o que tenga para sí, o de este otro modo: APREHEN-
DE lo mismo se ha legado *per vindicationem*. ⁵⁸

El legatario, en este caso, adquiría el legado en pro-
piedad quiritaria (*dominium ex iure quirritium*) lo que lo ha-
bilitaba a ejercer la acción reivindicatoria contra cualquiera
que tuviese la cosa legada.

Si el legado consistía en cosas fungibles, bastaba
con que el testador tuviera sobre ellas la propiedad al mo-
mento de la muerte. Si las cosas no eran fungibles, debía te-
ner el *dominium ex iure quirritium* en dos momentos: en el
del testamento y en el de la muerte.

Si una cosa era legada conjuntamente a varios lega-
tarios, cada uno de ellos adquiría una cuota igual. No sien-
do aceptada la parte por uno de ellos, los demás acrecían en
su favor.

Se discutía entre proculeyanos y sabinianos, quién
era el propietario de la cosa cuando el legado estaba sujeto
a condición y mientras ésta no se hubiese cumplido. Los
primeros sostenían que era *res nullius*. Para la otra escuela
y para la mayoría de los juristas, la cosa era propiedad del
heredero mientras no se cumpliera la condición.

b) *legatum per damnationem* (legado de obligación):

“Legamos *per damnationem* de este modo: QUE MI HE-
REDERO SEA CONSTREÑIDO A DAR A MI ESCLAVO
STICHUS, y aún si se hubiera escrito: QUE DE, lo mismo
se ha legado *per damnationem*.” ⁵⁹

Por esta forma se podía legar aún la cosa ajena, sig-
nificando ello que el heredero debía adquirirla para el lega-
tario. En el caso de que no pudiese adquirirla, estimaba el va-
lor de ella (*æstimatio*) y le entregaba el dinero al legatario.

⁵⁸ G. II, 193

⁵⁹ G. II, 201

También están comprendidos en este legado las cosas futuras, como los frutos que nacerán en tal fundo, o el hijo que naciera de tal esclava.⁶⁰

c) *legatum sinendi modo* (legado permisivo):

“Legamos *sinendi modo* de la siguiente forma: QUE MI HEREDERO TENGA QUE TOLERAR QUE LUCIUS TITUS TOME Y ADQUIERA PARA SI A MI ESCLAVO STICHUS.”⁶¹

Aquí el heredero estaba obligado a una conducta pasiva: permitir que el legatario se adueñara de la cosa legada.

Esta clase de legado es más amplio que el legado *per vindicationem* pero menos amplio que el legado *per damnationem*. En el primero (*legatum per vindicationem*) solo se podían legar cosas de propiedad del testador. En el segundo (*legatum per damnationem*) cosas del testador, del heredero o de un tercero. En cambio, en el legado *per sinendi modo* sólo se podían legar cosas del heredero o del testador, pero nunca de un extraño. Este legado es válido aún cuando la cosa no perteneciese ni al testador ni al heredero al momento de realizarse el testamento. Basta con que pertenezca a alguno de los dos al momento de la muerte del testador.

Lo que se discutía entre los juristas era si el legado era válido en el caso de que la cosa era de propiedad de un tercero y había comenzado a pertenecer al heredero después de la muerte del testador. La mayoría de los jurisperitos opinaba que tal legado era inútil. Esta polémica concluyó por aplicación del SC *Neronianum*⁶², por el que, con el objeto de atenuar la rigidez de las formas de los legados, se

⁶⁰ G. II, 203

⁶¹ G. II, 209

⁶² Senadoconsulto atribuido a Nerón Claudio, conocido como Nerón, quien gobernó Roma entre los años 54 al 68 dC.

dispuso que si un legado no cumplía con los requisitos impuestos a los legados *per vindicationem* o *per sinendi modo*, el mismo fuera válido como legado *per damnationem*, el más amplio de ellos.

d) *legatum per praeceptionem* (legado de preferencia):

“Legamos *per praeceptionem* de este modo: QUE LUCIUS TITUS RECIBA POR ADELANTADO A MI ESCLAVO STICHUS.”⁶³

Para la mayoría de los juristas, incluidos los de la escuela de los sabinianos, este legado solo puede ser realizado en favor de quienes habían sido instituidos como herederos. Los proculyanos sostenían que también podía ser otorgado en favor de los no instituidos.

Los sabinianos piensan que este legado en favor de extraños no puede ser validado ni aún por aplicación del SC Neroniano, pues esta disposición legal era aplicada solo a los legados que padecían del vicio de las palabras (*vitium verbis*), pero no a aquellos que no se deben por causa de la persona misma del legatario. GAYO sostiene que el legado *per praeceptionem* hecho a un extraño era de ningún valor.⁶⁴

Este legado entraña la preferencia del heredero respecto de determinada cosa, además de su porción hereditaria.

El primero y el cuarto legado (*legatum per vindicationem* y *legatum per praeceptionem*) generan para el legatario un derecho real sobre la cosa objeto del legado. En cambio, los legados nominados en segundo y tercer término (*legatum sinendi modo* y *legatum per damnationem*) generan un derecho de crédito contra el heredero y a favor del legatario.

⁶³ G. 2, 216

⁶⁴ G. 2, 218

29.- Reducción de los legados

Tal como lo referencia GAYO⁶⁵, en las primeras épocas de Roma, el testador podía agotar la totalidad del patrimonio hereditario destinándolo a legados. En estos casos era frecuente que el heredero instituido no aceptara la herencia, lo cual la convertía en *ab intestato*, salvo que se hubiese designado heredero sustituto. Si se trataba de *heredes sui*, estos podían optar por el *ius abstinendi*, lo que traía como consecuencia la ineficacia de los legados.

A fin de evitar estos inconvenientes se dicta, al promediar la república, la *lex Furia testamentaria*. Por ella se disponía que, salvo que se tratase de cognados hasta el sexto grado y hasta el séptimo grado en el caso del hijo del primogenito⁶⁶, el testador no podía disponer legados superiores a 1.000 ases. El legatario que aceptase legados superiores a esta suma era castigado con la pena del cuádruplo, que le podía ser exigida mediante la *manus iniectio pro iudicatio* pura.⁶⁷

Esta ley era fácilmente burlada, al disponer los testadores varios legados, ninguno de ellos superior a 1.000 ases. Por eso aparece la *lex Voconia* (169 a C) por la que se establece que ningún legatario puede obtener una suma mayor que el heredero. Tampoco fue solución, ya que el testador podía disponer de la totalidad del acervo hereditario, distribuyéndolo entre muchos legatarios, lo que tornaba ilusoria la herencia para los herederos.⁶⁸

La resolución del problema, llega con la ley Falcidia (40 aC) que deroga las limitaciones impuestas por las

⁶⁵ G. II, 224

⁶⁶ Fr. Vat. 301

⁶⁷ En este tipo de procedimiento ejecutivo (*manus iniectio pura*) no era necesaria la presencia del *vin-dex*, siendo ello requisito en la *manus iniectio iudicati* (G. IV, 21) y la *manus iniectio pro iudicato* (G. IV, 22). Estas acciones aparecen en la LXIIII^{as}, III y reproducidas en Gel. N.A. XX, 1.

leyes Furia testamentaria y Voconia e impone la reducción proporcional de los legados que en su conjunto superasen las tres cuartas partes de la herencia, de modo tal que quedase para los herederos la cuarta parte del acervo sucesorio.

La acción de la *lex Falcidia* correspondía al heredero, realizándose el cálculo de la cuarta parte sobre el patrimonio neto, una vez deducidas las deudas, las manumisiones y los gastos.

30.- Fideicomisos

Mediante el fideicomiso (*fidei committere*) el testador encomendaba al heredero o al legatario la realización de una determinada actividad en favor de un tercero (*fideicomisario*).

Los términos en que se dirigía el fideicomiso no eran, como en el caso del testamento o del legado, imperativos. El fideicomiso consiste en un ruego, una súplica para que alguien realice, a la muerte del testador, un determinado acto que beneficie al fideicomisario. En razón de ello las palabras que contiene la cláusula fiduciaria son distintas a las que contiene la institución de heredero y podían ser cualquiera de las que siguen: "pido, ruego, quiero, confío en tu buena fe".

El fideicomiso parece nacer de los obstáculos que debía afrontar el testador respecto de la capacidad testamentaria pasiva de ciertas personas a quien él quería beneficiar. Así las mujeres, que por la ley Voconia no podían ser instituidas herederas en herencias superiores a cien mil ases, podían recibir estas herencias por fideicomisos.⁶⁹ Lo

⁶⁹ G. II, 274

mismo los latinos, a quien les impide recoger herencias y legados la *lex Iunia*. Los peregrinos, los célibes y los *orbis*, estos dos últimos en virtud de lo dispuesto por las leyes caudarias de Augusto.

En un principio, las disposiciones del *ius civile* no otorgaban eficacia alguna a los fideicomisos. Se entendía que solo consistían en encomendar algo a la buena fe de una persona. En el período imperial, se asigna trascendencia jurídica a los fideicomisos, designándose magistrados especiales, encargados de hacer cumplir estas disposiciones testamentarias. Así el emperador Claudio designa dos Pretores Fideicomisarios, cumpliendo estas funciones, en las provincias, los gobernadores.

El testador podía, por el fideicomiso, transmitir toda la herencia (fideicomiso universal) o solo una parte de ella (fideicomiso singular). En el caso del fideicomiso universal, intervienen tres personas: el testador, el heredero fiduciario y el fideicomisario, a quien el heredero debía transmitir toda la herencia.

En las primeras épocas de Roma el fideicomisario que recibía la herencia no era considerado ni heredero ni legatario. Ello ocasionaba serios problemas al heredero y al fideicomisario. El heredero no podía evitar ser demandado en razón de la herencia y el fideicomisario no podía ejercer las acciones que le hubieran correspondido. Por eso, al recibir la herencia, el fideicomisario pactaba con el heredero el derecho de poder ejercer las acciones hereditarias en representación del heredero, y, a su vez, el heredero hacía prometer al fideicomisario que éste respondería por los perjuicios que le ocasionaran las demandas basadas en virtud de la herencia. El SC Trebeliano (56 dC) aportó las solucio-

nes a estas cuestiones, colocando al fideicomisario en el lugar que le correspondía al heredero. El Pretor le concedía acciones útiles para defender sus derechos. El heredero, por su parte, contaba con la *exceptio restitutæ hereditatis* para poder repeler las demandas que se le promovían.

El SC Pegasiano, de la época de Vespasiano, emperador entre los años 69 y 79 dC, extendió la aplicación de la ley Falcidia a los fideicomisos. Ello posibilitó que el heredero obligado a restituir la herencia al fideicomisario pudiese retener para sí la cuarta parte de la misma.

31.- Codicilos

El codicilo es una disposición patrimonial *mortis causa* desprovista de formalidades, realizada fuera del testamento.

Ello surge de las dificultades de quien se encontraba fuera de Roma para encontrar siete testigos ciudadanos romanos púberes como para realizar un testamento válido. Además de los testigos, debían cumplirse en el testamento otros recaudos, tales como la institución solemne e inequívoca del heredero. PAULO⁷⁰ refiere un caso en el que alguien instituyó al heredero verbalmente, haciendo constar los legados por escrito. En tal caso, según la opinión de JULIANO, no se considera que hubo testamento válido sino que se trata de un codicilo, por no haberse escrito el nombre del heredero.

El primer caso que se refiere a codicilos, aparece en textos romanos de la época de Justiniano.⁷¹ De acuerdo al

⁷⁰ D. 29, 7, 20

⁷¹ Inst. II, 25, pr.

texto, la validez de los codicilos se remonta a tiempos de Augusto. Se trata del caso de Lucio Lentulo, quien próximo a morir en Africa, escribió codicilos, que su testamento confirmaba, y donde disponía fideicomisos. Luego, hasta el mismo LABEON redactó codicilos, con lo que se completó la aceptación generalizada de los mismos.

El codicilo podía ser confirmado en pretérito, cuando el testamento se refiere a un codicilo redactado con anterioridad a éste; o en futuro, cuando, en el testamento, el testador se reserva el derecho de redactar codicilos posteriores. Como también la confirmación podía ser realizada en presente, cuando el testador se refiere a legados que se disponen en codicilo, simultáneamente con el testamento.

Los codicilos son considerados como elemento accesorio del testamento. Si el testamento resultaba inválido, el codicilo no tenía eficacia.

Se consideraba, ficticiamente, que el codicilo había sido redactado en el mismo momento que el testamento. Así, refiere JULIANO⁷², no se puede conceder la libertad de un esclavo que pertenecía al *dominus* en el momento de redactarse el testamento, pero que era ajeno cuando se hizo el codicilo.

En un principio, los codicilos no eran válidos sino estaban confirmados en el testamento. Luego, con Trajano, se le otorga al codicilo validez aún en el caso de no existir testamento (*codicilo ab intestato*).

El codicilo era limitado en cuanto se refiere a las disposiciones que podía contener: no eran válidas las instituciones o sustituciones de herederos. Pero sí podían realizarse por este instrumento legados, manumisiones y desig-

⁷² D. 29, 7, 2, 2

⁷³ CTh. 4, 4, 1
⁷⁴ CTh. 4, 4, 7, 2
⁷⁵ C. 6, 36, 8
⁷⁶ CTh. 4, 4, 7, pr.

naciones de tutores, siempre que fuesen confirmados en el testamento. En tanto, los fideicomisos y sus revocaciones podían ser el contenido de codicilos *ab intestato*.

En el período postclásico, aparecen disposiciones imperiales que exigen, para la validez de los codicilos, algunas formalidades. Así, Constantino determina, para la validez del codicilo *ab intestato*, la presencia de cinco testigos⁷³ requisito que Teodosio II eleva a siete testigos, extendiendo esta solemnidad a los codicilos confirmados en testamento.⁷⁴ Justiniano reduce el número de testigos a cinco, pero exige sus firmas y sus sellos.⁷⁵

También podía incorporarse al testamento la denominada cláusula codicilar, por la que el testador expresaba que de no ser válido el testamento, valiera el mismo como codicilo. Si la referida cláusula había sido puesta en un testamento inválido, la sucesión era *ab intestato*, pero las disposiciones testamentarias valían como codicilos *ab intestato*. En este caso la institución de heredero se convertía en un fideicomiso universal. Por ello, el heredero *ab intestato* debía restituir la herencia al heredero instituido en el testamento.

Teodosio II dispuso que si el testamento contenía cláusula codicilar, el que era instituido heredero podía optar entre ser heredero o fideicomisario universal.⁷⁶

FRANJA MORADA

32.- Capacidad del heredero ab intestato

Los esclavos no podían adquirir la herencia *ab intestato*. Solo podían ser instituidos por testamento si se los manumitía en ese mismo acto, efectivizándose su libertad cuando el testador moría. Si el esclavo instituido heredero no pertenecía al testador, para aceptar la herencia necesitaba el *iussum* de su dueño, pasando la herencia al patrono.

Los *filiusfamilias* no podían ser herederos *ab intestato*, pues la plena capacidad jurídica solo se le otorgaba al *Paterfamilias*. En épocas del imperio, tal situación se modifica ya que las familias se dividen al formar los *filius* las suyas, formándose para el *filius* un patrimonio propio, distinto del de su *Pater*.

Los extranjeros (peregrinos) no pueden ser herederos *ab intestato* cuando el causante es ciudadano romano. Sin embargo, los extranjeros podían sucederse entre sí, de acuerdo con las leyes de su ciudad.

Tampoco podían ser herederos *ab intestato* los romanos que hubieran sido condenados por *crimina*.⁷⁷

Los *latini iuniani* (latino junianos) podían ser herederos legítimos, en virtud de la *lex Junia Norbana*. (19 dC).

Las mujeres, en el derecho primitivo, tenían plena capacidad para suceder. Luego, la *lex Voconia* (169 aC) dispuso serias limitaciones respecto del testamento, y que una constitución imperial limitó, en la herencia *ab intestato*, a las hermanas consanguíneas.⁷⁸ En el derecho imperial se excluye de la sucesión legítima a los herejes, los apóstatas y a los condenados por el delito de alta traición. La viuda que se había casado dentro del año de la muerte de su es-

⁷⁷ *Crimina* es el acto ilícito que merece pena pública. Así el parricidio (homicidio del hombre libre) o el perduellio (alta traición)

⁷⁸ C. 6, 58, 14 y 15

pos, solo podía suceder a sus parientes hasta el tercer grado.

Respecto del *nasciturus*, la Ley de las Doce Tabas dispone que para incluir en la herencia legítima el hijo póstumo éste debe haber nacido dentro de los 300 días posteriores a la muerte del padre.⁷⁹

33.- La ley de las XII Tabas

Si no había testamento o éste era inválido, la sucesión era *ab intestato*. Modernamente se denomina a esta herencia legítima, pues ya no se rige por el testamento sino de acuerdo a las disposiciones de la ley. En el derecho romano primitivo era la ley de las Doce Tabas la que regulaba esta sucesión.

“ Si alguien muere sin testamento y no existe ningún *filiusfamilias* heredero, el agnado más próximo tenga la herencia. Si no hay ningún agnado, tengan la herencia los gentiles.”⁸⁰ Esta regulación implica tres llamamientos a la sucesión legítima. En el primero son convocados los herederos sui, es decir los que se encuentran bajo la *patria potestas* del *Pater* al momento de su muerte.

Este llamamiento comprende a los hijos legítimos, nacidos de justas nupcias, los hijos legitimados⁸¹, los adoptados, los adrogados y la *uxor in manu*⁸².

⁷⁹ LXIIIffs. IV, 4; D. 38, 16, 3, 11

⁸⁰ LXII Tbs. V, 4 y 5; Ulp. 26, 1; D. 50, 16, 195

⁸¹ En Roma el procedimiento de legitimación de hijos naturales, que provenían de concubinato, se creaba mediante *subsequens matrimonium* de los concubinos. Si alguno de ellos hubiese fallecido se legitimaba por medio de un rescripto del príncipe, recurriéndose para esta decisión al Emperador. Otro modo resultaba de la oblación a la Curia, que significaba prometer que los hijos varones se desempeñarían como decuriones o las hijas mujeres se casasen con decuriones.

⁸² A los efectos sucesorios, se consideraba que la *uxor in manu* era hija de su marido y hermana de sus hijos. A este efecto se decía que era *loco filia*, ya que ocupaba el lugar de un hijo.

Además también se incluye aquí a los descendientes de los hijos del causante que han muerto o que han sido emancipados. Ellos concurren a la herencia en representación de sus padres que no pueden adir la herencia.

La sucesión, respecto de los *sui*, se transmite por *estirpe* y no por *cabeza*. Esto quiere decir que si, por ejemplo, existen tres hijos del causante la herencia se divide en tres partes, no importando el número de nietos o biznietos que concurren en representación de sus ascendientes premuertos. En este supuesto la *uxor in manu* hace que la herencia se divida en cuatro partes pues ella concurre como un hijo más, por una parte viril.

También eran herederos *sui* los hijos póstumos, nacidos después de la muerte del causante, como si al momento de la muerte del causante hubiesen estado bajo su patria potestad.

El sistema sucesorio decenviral se regía por el parentesco de agnación, parentesco civil que involucraba solo a aquellos descendientes que se encontraban bajo la patria potestad del causante al momento de su muerte. Así, las hijas del causante que estuviesen bajo la *manus* del *Pater* de su marido eran cognadas respecto del *Pater* de sangre y estaban excluidas de su herencia.

Si no existiesen *heredes sui* se procedía a efectuar el segundo llamamiento, que estaba destinado a los agnados más próximos.

Estos agnados son los que no han concurrido al primer llamamiento, los hoy denominados parientes colaterales, hermanos del causante o sus descendientes.

En este llamado no hay derecho de representación, transmitiéndose la herencia por *cabeza* y no por *estirpe*. Así,

si existen hermanos en condiciones de adir la herencia, hermanos premuertos y sus hijos (sobrinos del causante) solo podrán heredar los hermanos ya que la ley es terminante: los agnados más próximos. En este caso los hermanos del causante (parientes más cercanos) excluyen a los sobrinos (parientes más lejanos).

De no existir herederos que aceptaran la herencia, la ley efectuaba un tercer llamamiento, que era para los gentiles.

Los gentiles, según los juristas romanos, serían los miembros de la gens. Algunos romanistas, disconformes con un concepto tan genérico, dicen que, siguiendo la cita de CICERON, los gentiles son aquellos que tienen un mismo nombre, que desde su origen son ingenuos, que no han servido en esclavitud, que no sufren *capitis deminutio*. DI PIETRO⁸³, sobre el tema, piensa que esta definición versa más bien sobre los aspectos exteriores de la gentilidad sin penetrar en cauces más profundos como eran los del origen de la estructura familiar romana.

“ Por el derecho de una relación especial llamamos familia al conjunto de personas que están bajo una misma potestad, sujetas a ella por nacimiento o por un acto de derecho. Por el derecho común de parentesco llamamos familia a la de todos los agnados, porque, aunque, al morir el cabeza de familia, todos tienen sus propias familias, sin embargo todos los que estaban sometidos a la misma potestad se pueden llamar propiamente de su familia, pues proceden de la misma casa y stirpe ”⁸⁴

Ello se basa en la existencia de dos conceptos: el de la familia *proprio iure*, que comprende a todos los integrantes de la familia: *Pater*, esposa, hijos y sus descendien-

tes, adoptados, adrogados, libertos, clientes, esclavos, *in mancipi* y la familia *communi iure*, la que solo incluye a los agnados.

Respecto de la segunda acepción - familia *communi iure* - observa DI PIETRO que aún cuando las nuevas generaciones se van separando formando nuevas familias, continúan los parientes unidos en virtud del culto común a los dioses familiares, los dioses manes, los antepasados difuntos. Ello lo lleva a este autor a definir a la gens como corporación de familias reunidas por la necesidad del culto a antepasados comunes.

34.- Bonorum possessio

La *bonorum possessio ab intestato* comprendía cuatro llamamientos:

1) *unde liberi* (de parte de los hijos). A este primer llamado concurren los hijos legítimos del causante, incluidos los emancipados y en caso de haber alguno premuerto, sus descendientes.

Por un edicto del Pretor Juliano, que se conoce como cláusula Iuliani, en caso de concurrir un hijo emancipado con hijos que hubiesen quedado en potestad del causante, éste concurre por la mitad de la parte viril y sus hijos por la otra mitad.

Respecto de los emancipados el Pretor dispone, para recibir la *bonorum possessio*, debían dividir su propio patrimonio en favor de los no emancipados (*collatio bonorum*). Dábase así solución a las desigualdades económicas

83 DI PIETRO : Texto, traducción y notas a las Institutas de Gayo. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1987
84 D. 50, 16, 195, 2

que provenían de los patrimonios de los emancipados, frente a la ausencia de bienes respecto de los *sui*. A tales fines el emancipado, antes de recibir la *bonorum possessio*, debía prestar una *cautio de conferendis bonis*, en la que, por medio de una *stipulatio*, se obligaba con sus bienes existentes a la muerte del *Pater*.

2) *unde legitimi* (de parte de los legítimos): No contando hijos bajo potestas ni hijos emancipados, median te un segundo llamado el Pretor convoca a los agnados. En esta época ya habían desaparecido los gentiles.

3) *unde cognati* (de parte de los cognados): Si no existían agnados, el Pretor llama a los cognados. En este tercer llamado se incluye a los que habían perdido la agnación por *capitis deminutio*, ya que en tal caso se los consideraba cognados. El cognado de grado más próximo impedía adquirir la *bonorum possessio* a los de los grados subsiguientes.

4) *unde vir et uxor* (de parte del marido y de la esposa): En el cuarto llamamiento se incluía a la *uxor sine manus*.

35.- Senadoconsultos Tertuliano y Orficiano

La ley de las Doce Tablas, en relación a los vínculos de la madre en la sucesión de sus hijos y de los hijos en la sucesión de la madre., establecía normas dotadas de un excesivo rigorismo, excluyéndolos de tales herencias.

En el período pretoriano tales personas eran admitidos en el llamamiento *unde cognati*, como simples cognados, sin ningún tipo de preferencia.⁸⁵

Ya en la etapa imperial, aparece el SC Tertuliano (158 dC), por el que se otorga a las madres provistas del *ius liberorum*⁸⁶ el derecho de suceder a sus hijos intestados siempre que no existiesen descendientes, ni padre, ni hermanos consanguíneos.

Este SC no incorpora a la madre al orden de los herederos *ab intestato*, sino que le concede un privilegio especial, que estas madres debían obtener mediante un rescripto. Este privilegio solo se concedía a las madres respecto de la sucesión de sus hijos, no así a la de sus nietos.

El SC Orficiano (178 dC), otorga a los hijos la herencia de la madre legítima o natural por sobre los consanguíneos y los agnados de la madre.

Una constitución de Justiniano⁸⁷ incluye dentro de la sucesión *ab intestato* a todas las madres, incluso a aquellas a las que no se les hubiera concedido el *ius liberorum*.

36.- Las Novelas 118 y 127

Durante el gobierno de Justiniano se logra uniformar el sistema sucesorio, ya que las pautas del régimen hereditario se encontraban dispersas en diversas disposiciones legislativas, algunas de ellas confusas y otras contradictorias. Así, a través de una serie de disposiciones contenidas en constituciones imperiales, se logra esclarecer el panorama de los derechos hereditarios.

⁸⁵ Insts. 3, 3, 1

⁸⁶ El *ius liberorum* era una concesión de Augusto, por medio de sus leyes caducarias, a fin de promover el crecimiento demográfico, que liberó de la tutela *mulleris* a las mujeres ingenuas que tuvieran tres hijos o las libertas con cuatro hijos

⁸⁷ C. 8, 59, 1

Las Novelas 118 y 127 (543 y 548 dC) son las que se refieren a la sucesión *ab intestato*. Para ello se disponen cuatro llamamientos .

En el primer llamado se convoca a los descendientes legítimos . Existe aquí el llamado derecho de representación, por el que si uno de los descendientes ha premuerto al causante le suceden sus descendientes. Aquí la herencia se divide por cabeza , si todos los herederos son del mismo grado, y por stirpe si los hay de grados distintos. Si no existen descendientes, los hijos naturales obtienen 1/6 de la herencia, caso contrario solo el derecho de alimentos..

Si no existen descendientes, en el segundo llamado, concurren los ascendientes junto a los denominados hermanos gemelos. Estos son los hermanos del mismo padre y de la misma madre, o sus descendientes. Si solo existen ascendientes, la herencia se divide por mitades entre los ascendientes paternos y los ascendientes maternos Respecto de los ascendientes, el más cercano excluye al más lejano. En cambio, si alguno de los hermanos gemelos ha premuerto, le suceden por derecho de representación sus descendientes.

El tercer llamado es destinado a los hermanos consanguíneos - del mismo padre - y a los hermanos uterinos - de la misma madre, o sus descendientes

En el cuarto llamado acuden los cognados, no habiéndose determinado en las Novelas el límite del grado de parentesco.

En el caso de que no concurren cognados, la ley llama a heredar al cónyuge del causante. Si concurre con los hijos solo obtendrá una parte viril de la herencia. Si son sus propios hijos solo gozará del usufructo sobre dichos bienes.

Si no existen herederos, es el fisco el dueño de la herencia, la que es considerada vacante. Es bastante difícil que ello ocurra, ya que los bienes del sacerdote o el monje van a la Iglesia o a la Orden religiosa; si se trata de un decurión pasa el acervo sucesorio a la curia; la herencia del soldado a su legión; y si el causante era miembro de una corporación sus bienes se transmitirán a ella.

FRANJA MORADA

37.- Hereditatis petitio

La acción de petición de herencia (*actio hereditatis petitio*) le corresponde ejercerla al heredero, sea éste instituido por testamento o resulte de una sucesión *ab intestato*, a fin de que se le reconozcan sus derechos y contra cualquiera que lesione su carácter de tal.

Esta acción puede tener por objeto la restitución de bienes que pertenezcan al acervo hereditario o el reconocimiento de derechos de crédito que tenga el heredero a su favor.

La *hereditatis petitio* no es una acción que el heredero ejerce en nombre del causante, sino que le corresponde por su calidad de heredero. Así, si alguien a quien el heredero ha demandado niega al actor su calidad de tal, su legitimación activa.

La *hereditatis petitio* ya era ejercida en el más antiguo sistema procesal mediante la *legis actio per sacramentum*, aún cuando no se la conocía por ese nombre.

Su estructura era similar a la de la *actio reivindicatio*. En el derecho antiguo el heredero solo podía demandar a quien poseía la cosa *pro herede* (poseo porque soy heredero). Ya en el período clásico la acción se extiende al *possessor pro possessore* (poseo porque poseo).

Será el SC Iuventianum, bajo el gobierno de Adriano (129 dC) el que reglamente la institución, extendiendo la legitimación pasiva a quien ha cesado en la posesión. Es el caso del poseedor de mala fe⁸⁸ que ha dejado de poseer por haber vendido la cosa, quien debe el precio obtenido con más sus intereses. Si el poseedor es de buena fe, debe el precio sin los intereses.

⁸⁸ En D. 5, 3, 20, 6

Si el poseedor de mala fe no ha perdido la posesión deberá restituir la cosa, más todo aquello con que se hubiera enriquecido en razón de la posesión de las cosas hereditarias. Debía también los frutos percibidos, los pendientes, e incluso los no producidos o los no recogidos durante su posesión. Además debía responder por los daños y pérdidas sufridos por las cosas siempre que los mismos hubiesen acaecido durante su posesión.

El poseedor de buena fe, además de restituir la cosa deberá solo los frutos con que se ha enriquecido. Puede solicitar los gastos necesarios y los útiles, pero no los voluntarios.⁸⁹ Al de mala fe solo se le reconocen los gastos necesarios

38.- Defensa de los bonorum possessores

a) Interdicto *quorum bonorum*

Diversos fueron los medios procesales que esgrimió el Derecho Pretoriano en defensa de los *bonorum possessores*. Así, el interdicto *quorum bonorum*, definido por ULPiano⁹⁰ como: "De cuyos bienes se le dio la posesión por mi edicto, le restituirás lo que posees como heredero o como poseedor, o lo poseerás si nada se hubiese usucapido, y lo que has dejado dolosamente de poseer."

Este interdicto se refiere al conjunto de bienes, y no a las cosas singulares, obligando a restituir a todos los que poseen objetos corporales de la herencia. Se dirige tanto contra el poseedor *pro herede* como contra el poseedor *pro possessore*. El interdicto era ejercido por los *bonorum pos-*

⁸⁹ Los gastos necesarios son aquellos que, de no haberse efectuado, hubiesen puesto en peligro la integridad de la cosa. Los útiles son los que aumentan el valor de la cosa. Los voluntarios, también llamados sumptuarios, son los que solo benefician al que los ha realizado.

⁹⁰ D. 43, 2, 1, pr.

sessores para conseguir la restitución de los bienes hereditarios. En el derecho de Justiniano, la posibilidad de promover el interdicto se extiende al heredero civil.

b) *actio hereditatis petitio possessoria*

Otro de los medios procesales que se le conceden al *bonorum possessor*, conocido como la *actio hereditatis petitio possessoria*, es de la época de Justiniano. Aparece en el Digesto⁹¹ como petición posesoria de la herencia. El pretor concede esta acción al *bonorum possessor* a fin de que este pueda lograr lo mismo que el heredero del derecho civil mediante la *actio hereditatis petitio*.

c) Acciones ficticias

GAYO⁹² se ocupa de estas acciones en sus Institutas. La situación surge porque, de acuerdo al derecho civil, el *bonorum possessor* no tiene acciones para reclamar la herencia, dado que no es heredero.

Entonces el Pretor, tal como en el caso de la *actio publiciana in rem*, autorizaba al *bonorum possessor* a ejercer acciones relativas a la herencia. Mediante estas acciones ficticias el *bonorum possessor* pide la herencia fingiéndose heredero.

Por eso estas acciones se denominaban ficticias, ya que el *bonorum possessor* finge ser heredero.

d) interdicto *quod legatorum*

Mediante este interdicto el Pretor pretende que

⁹¹ D. 5, 5, 1 y 2.

⁹² G. IV, 34

quien detenta una cosa como legatario, sin el consentimiento del heredero, debe devolverla al heredero, quien está obligado por los legados.

ULPIANO⁹³ es quien mejor lo conceptualiza: "el interdicto consiste en lo que se ocupa a causa de legado, sin el consentimiento del heredero, debe restituirse al heredero. Ha parecido muy justo al Pretor que no se adjudique uno por sí y ante sí los legados por ocupación de los mismos, sino que los pida al heredero. El Pretor devuelve pues a los herederos, por medio de este interdicto, lo que alguien posee en concepto de legado, para que ; luego puedan demandarle los legatarios."

GARCIA GARRIDO⁹⁴ piensa que el texto se limita a recordar la regla de que nadie puede tomarse la justicia por su mano y que el legatario no puede ocupar por sí mismo los bienes legados sino que debe pedir su entrega al poseedor hereditario o al heredero.

El interdicto tenía por finalidad el impedir que el que poseía como legatario se convirtiese por usucapión en propietario.

En el derecho pretoriano, quien podía intentar el interdicto era el *bonorum possessor*. Ya en la época de Justiano, habiéndose fundido el derecho civil y el pretoriano, el interdicto también podía ser intentado por el heredero, contra quien se atribuía la calidad de legatario o poseyese cosas del acervo hereditario.

⁹³ D. 43, 3, 1, 1 y 2

⁹⁴ GARCIA GARRIDO : Derecho Privado Romano. Dykinson. Madrid, 1995

39.- Medios judiciales en favor de los legatarios

Tal como se dijo al abordar el tema de las distintas clases de legados, los denominados *per vindicationem* y el *per praeceptionem* otorgan al legatario un derecho real sobre la cosa objeto del legado. En cambio, los legados *sinendi modo* y *per damnationem* generan un derecho de crédito contra el heredero y a favor del legatario.

Por eso, en los legados *per vindicationem* y *per praeceptionem*, el legatario adquiría la propiedad quiritaria respecto de las cosas legadas, pudiendo ejercer la acción reivindicatoria.⁹⁵

En el legado *per praeceptionem*, si el causante tenía la cosa *in bonis*, el legatario podía conseguir la cosa mediante la *actio familiae erciscundae* (acción de partición de herencia).

En los otros dos legados - *sinendi modo* y *per damnationem* - el legatario va ante el magistrado para ejercer una *actio in personam*.⁹⁶

En estos casos, el heredero debía prestar al legatario la *cautio legatorum servandorum causa*, a fin de garantizar el cumplimiento del legado. Si el heredero se negaba a prestar la *cautio*, el Pretor ponía en posesión de la cosa legada al legatario mediante la *missio in possessionem servandorum causa*.

40.- Actio Familiae Erciscundae

Parecería que esta acción de partición de herencia - *actio familiae erciscundae* - nace a principios de la república

⁹⁵ G. II, 194 y 222

⁹⁶ G. II, 204 y 213

y ya figura dentro del texto de la ley decenviral⁹⁷ Ello en razón de que en la ley de las XII Tablas había figuras jurídicas que surgieron con ella y otras que la ley institucionalizó.⁹⁸

Durante la monarquía y teniendo en cuenta el concepto de *hereditas* se entiende que ninguno de los herederos podría haber planteado judicialmente la división de la herencia, dado el carácter del patrimonio familiar. GAYO confirma esta idea, cuando dice que antiguamente, a la muerte de un *paterfamilias*, existía entre los *sui heredes* una sociedad a la vez legítima y natural, que se llamaba *ercto non cito*, es decir dominio indiviso.⁹⁹

La *actio familiae erciscundae* es una de las tres acciones divisorias que conocieron los romanos junto a la *actio communi dividundo* - acción de división de la cosa común- que era propia del condominio y la *actio finium regundorum*, que se refería a las cuestiones de límites entre propietarios de inmuebles.

En el más antiguo de los sistemas procesales romanos, la partición se lograba mediante la acción declarativa denominada *legis actio per iudicis postulationem* (acción de la ley por postulación de juez).¹⁰⁰

En el proceso formulario, cuando la *intentio* consistía en la pretensión jurídica de partir una herencia, la fórmula se elabora sin *condemnatio*, la que se reemplaza por una *adiudicatio*. El magistrado no le ordena al *iudex* que condene sino que adjudique.

⁹⁷ Ley XII Tabs. V, 10

⁹⁸ MUJER: La ley de las Doce Tablas, p. 11. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, La Plata, 1994

⁹⁹ G. : III, 154a

¹⁰⁰ G. : IV, 17a

Bibliografía
Obras consultadas

- AMBROSIONI : - El concepto de la sucesión universal en el Derecho Romano. Revista del Colegio de Abogados de La Plata. p. 73. La Plata, 1972
- Ensayo sobre una sistematización de los hechos y actos jurídicos en el derecho romano. Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. T. XXI, p. 135. La Plata, 1962.
- ALVAREZ SUAREZ : Curso de Derecho Romano. Ed. Revista de Derecho Privado. Madrid, 1955
- ARANGIO RUIZ : - Historia del Derecho Romano. Instituto Editorial Reus. Madrid, 1943
- Las acciones en el Derecho Privado Romano. Editorial Revista de Derecho Privado. Madrid, 1945
- ARGUELLO : Manual de Derecho Romano. Astrea, Buenos Aires, 1992
- AULO GELIO : Noches Aticas. Librería de Perlado, Paez y Cia., Madrid, 1921
- BETTI : Istituzioni di Diritto Romano. Padua, 1947
- BONFANTE: - Istituzioni di Diritto Romano. Dott. A. Giuffrè Editore. Milano, 1987
- Corso di Diritto Romano. Attilio Sampaolese Editore. Roma, 1925
- CRIFO : La legge delle XII tavole. Osservazioni e problemi. Roma, 1972

FRANJA
MORADA

CUERPO DEL DERECHO CIVIL ROMANO. Texto y traducción de Ildefonso L. García del Corral. Madrid, 1889

DE CRESCENZIO : II Digesto Italiano. Torino, 1889

DIGESTO DE JUSTINIANO. Versión castellana de A. D'Ors, F. Hernandez Tejero, P. Fuentesea, M. García Garrido y J. Burillo. Editorial Aranzadi, Pamplona, 1978

DI MARZO : Istituzioni di Diritto Romano. Milano, 1945

DI PIETRO : Texto, traducción y notas a las Institutas de Gayo. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1987

DONELO : Libros de Comentarios sobre el Derecho Civil. Florencia, 1841

FADDA : Conceptos fundamentales del derecho hereditario romano. Milano, 1949

FRAGMENTOS VATICANOS . Estudio preliminar de Alvaro D'Ors. Tecnos. Madrid, 1988

FUSTEL DE COULANGES : La ciudad antigua. Selene. Buenos Aires, 1985

GARCIA GARRIDO : Derecho Privado Romano. Dykinson, Madrid, 1995

IGLESIAS : Derecho Romano. Ariel Derecho, Barcelona, 1983

INSTITUCIONES DEL EMPERADOR JUSTINIANO. Textos y comentarios de M. Ortolan. Librería de D. Leocadio Lopez. Madrid, 1884.

JORS / KUNKEL: Derecho Privado Romano. Editorial Labor, Barcelona, 1937

...essione ereditaria intestata e contro il testamento romano. Firenze, 1930

LOPEZ-BARAJAS MIRA: Separatio Bonorum. Instituto de Historia del Derecho. Universidad de Granada. Granada, 1995

LOUZAN DE SOLIMANO Curso de Historia e Instituciones de Derecho Romano. Buenos Aires, 1994

MIQUEL : Curso de Derecho Romano. PPU. Barcelona, 1987

MOJER : La ley de las Doce Tablas. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. La Plata., 1994

MOMMSEN : Historia de Roma. Aguilar, Madrid, 1987

PEROZZI: Istituzioni di Diritto Romano. G. Barbera Editore, Firenze, 1906

PETT : Manual Elemental de Derecho Romano. Editorial Albatros, Buenos Aires, 1977

RASCON GARCIA / GARCIA GONZALEZ : Ley de las Doce Tablas. Tecnos, Madrid, 1993

SCHULZ : Derecho Romano Clásico. Casa Editorial Bosch. Barcelona, 1960

TALAMANCA : Istituzioni di Diritto Romano. Dott A. Giuffrè Editore. Milano, 1990

ULPIANO: Reglas. Notas y traducción de Nina Ponsa de la Vega de Miguens. Ediciones Lerner, Buenos Aires, 1970

CUERPO DEL DERECHO CIVIL ROMANO. Texto y traducción
Madrid, 1889

WIEACKER : Historia del derecho privado en la Roma
Ed. Aguilar, Madrid, 1957

FRANJA
MORADA